<제4편 소송의 종료.제10장 종국판결에 의한 종료.제02절 판결.00>

Ⅰ. 판결의 종류

1. 중간판결[민소법 제201조]

(1) 의의

- 중간판결이란 그 심급에 있어서 사건의 전부 또는 일부를 완결하는 종국판결을 하기 전에 그 종국판결의 전제가 되는 개개의 쟁점사항에 대하여 미리 정리하고 판단하여 종국판결을 용이하게 하는 판결을 의미한다(민소법 제201조).

(2) 중간판결사항

- 다른 공격방어방법과 무관하게 분리독립하여 심리할 수 있는 독립한 공격방어방법이나, 청구에 대한 판단으로 나아가기 전에 판단해야 할 그 밖의 중간의 다툼뿐만 아니라 청구의 원인과 액수에 관한 다툼이 있는 경우 그 원인에 대하여도 중간판결을 할 수 있다. 종국판결

2. 종국판결[민소법 제198조]

- 종국판결이란 소·상소에 의하여 계속된 사건의 전부나 일부에 관하여 해당심급에서 완결하는 판결을 말한다. 본안판결·소각하판결·소송종료선언 등이 이에 속하며 항소법원의 환송판결과 대법원의 환송판결도 그 심급을 이탈시키는 판결이라는 점에서 종국판결이다. 종국판결은 사건을 완결시키는 범위에 따라 전부·일부·추가판결로 구분되고 소의 적법요건에 대한 판단인지 또는 청구의 당부에 대한 판단인지에 따라 소송판결과 본안판결로 구분된다.

Ⅱ. 기판력 개관

1. 서설

(1) 기판력의 의의

- 기판력이란 확정된 종국판결의 내용이 가지는 후소에 대한 구속력을 말한다. 즉, 기판력이란 기판력 있는 전소판결의 소송물과 동일한 후소를 허용하지 않는 것임은 물론, 후소의 소송물이 전소의 소송물과 동일하지 않다고 하더라도 전소의 소송물에 관한 판단이 후소의 선결문제가 되거나 모순관계에 있을 때에는 후소에서 전소판결의 판단과 다른 주장을 하는 것을 허용하지 않는 작용을 하는 것(대판 1995.3.24. 94다46114)을 의미한다.

(2) 정당성의 근거

- 기판력은 동일한 사항이 후소에서 다시 문제되는 경우 당사자가 다시 그에 반하여 다투거나 법원이 그와 모순·저촉되는 판결을 하지 못하게 함으로써 법적 안정성을 확보하려는 것이다.

(3) 직권조사사항 및 소송요건

- 기판력은 직권조사사항이며 승소확정판결이 없을 것은 판례의 모순금지설에 의할 때 권리보호이익의 요건으로 소송요건이다. 따라서 전소에서 승소확정판결을 받은 뒤에 동일한 후소를 제기하면 권리보호이익의 흠결로 후소를 각하하여야 한다. 전소확정판결의 기판력과 모순·저촉되는 판결은 무효가 아니며 위법한 판결이므로 확정 전이면 상소로, 확정 후이면 재심에 의하여 다툴 수 있다. 그러나 뒤의 확정판결은 취소될 때까지는 새로운 표준시의 판결로써 기판력을 가진다는 것을 유의하여야 한다.

2. 기판력 있는 재판

(1) 유효하게 확정된 판결

① 유효한 판결

- 당사자 사망의 경우처럼 당사자대립구조가 무너진 경우, 재판권이 없는 경우, 당사자적격이 없는 경우 등 하자가 중대한 경우 그 판결은 당연무효이고 무효인 판결에는 기판력이 발생하지 않는다. 다만, 하자 있는 판결이라도 무효인 경우를 제외하고는 위법하지만 유효인 판결이므로 기판력이 발생한다.

② 확정된 종국판결

- 본안판결이라면 청구인용판결이든 청구기각판결이든 기판력이 발생한다. 확정된 종국판결이어야 하므로 미확정판결이나 중간판결에는 기판력이 발생하지 아니한다. 소송판결도 소송요건의 흠결로 소가 부적법하다는 판단에 한하여 기판력이 발생한다. 어떠한 소송요건이 흠결로 판단된 것인가는 판결이유를 참작할 것이며 이에 의하여 정하여지는 소송요건의 흠에 대한 판단에만 기판력이 발생한다. 판례는 소송판결의 기판력은 그 판결에서 확정한 소송요건의 흠결에 관하여 미치는 것이지만, 당사자가 그러한 소송요건의 흠결을 보완하여 다시 소를 제기한 경우에는 그 기판력의 제한을 받지 않는다(대판 2003.4.8. 2002다70181)고 판시하고 있다.

(2) 결정·명령

- 소송비용에 관한 결정, 간접강제를 위한 배상금의 지급결정 등 실체관계를 종국적으로 해결하는 경우에만 기판력이 발생한다. 따라서 가처분·가압류결정 등 보전처분절차는 피보전권리를 종국적으로 확정하는 것이 아니므로 피보전권리의 존부에 대해 기판력이 발생하지는 아니한다.

(3) 확정판결과 동일한 효력이 있는 조서

- 확정판결과 동일한 효력이 있는 청구의 포기·인낙조서, 화해조서(민소법 제220조), 화해권고결정(민소법 제231조), 조정조서(민사조정법 제29조), 조정에 갈음한 결정(민사조정법 제34조) 등에는 기판력이 인정된다. 그러나 이행권고결정과 지급명령은 집행력은 인정되나 기판력은 인정되지 아니한다(대판 2009.5.14. 2006다34190).

(4) 외국법원의 확정판결

- 외국법원의 확정판결은 민사소송법 제217조 제1항 각 호의 요건을 갖추어 우리나라에 승인될 수 있으면 기판력이 발생한다. 따라서 외국법원의 확정판결과 동일한 소송을 국내에서 제기하면 기판력에 저촉된다(대판 1987.4.14. 86다카957). 최근 판례는 민사소송법 제186조 제1항과 제2항에서 규정하는 보충송달도 교부송달과 마찬가지로 외국법원의 확정재판 등을 국내에서 승인·집행하기 위한 요건을 규정한 민사소송법 제217조 제1항 제2호의 `적법한 송달`에 해당한다고 해석하는 것이 타당하다고 하면서, 보충송달은 민사소송법 제217조 제1항 제2호에서 외국법원의 확정재판 등을 승인·집행하기 위한 송달 요건에서 제외하고 있는 공시송달과 비슷한 송달에 의한 경우로 볼 수 없고, 외국재판 과정에서 보충송달 방식으로 송달이 이루어졌더라도 그 송달이 방어에 필요한 시간 여유를 두고 적법하게 이루어졌다면 적법한 송달로 보아야 하므로 보충송달이 민사소송법 제217조 제1항 제2호에서 요구하는 통상의 송달방법에 의한 송달이 아니라고 본 종전의 판례들을 변경하였다(대판 2021.12.23. 2017다257746[전합]).

(5) 소송물에 대한 실질적 판단

- 기판력이 발생하기 위해서는 법원이 소송물인 권리관계에 대하여 실질적으로 판단하여야 한다. 판례도 1필지 토지 전부에 대한 소유권이전등기청구소송에서 토지 일부의 매수사실은 인정되나 특정할 수 없다는 이유로 전부패소판결을 받아 확정된 후 매수 부분을 특정하여 소유권이전등기를 구하는 경우 전소에서는 그 부분을 매수하였는지 여부, 즉 권리관계의 존부에 대하여 실질적으로 판단이 되었다고 할 수 없으므로 전소는 매수 부분에 관한 한 기판력이 생기지 아니한다(대판 1992.11.24. 91다28283)고 하여 같은 취지로 판시하고 있다.

3. 기판력의 본질

(1) 학설

- 기판력을 재판통일을 위해 전소 확정판결과 모순된 판단을 금지하는 효력이라고 보고 전소에서 승소판결을 받은 원고가 다시 동일한 소를 제기하면 권리보호이익의 흠결로 후소를 각하하고, 패소판결을 받은 원고가 다시 동일한 소를 제기하면 전소와 모순되는 판단의 금지의 구속력 때문에 청구기각판결을 하

여야 한다고 보는 모순금지설과 기판력을 분쟁해결의 일회성을 위해 후소법원에 대해 한 번 확정된 법률효과에 대해 다시 변론이나 재판하는 것 자체를 금지하려는 효력으로 이해하여 승패를 불문하고 동일한 후소를 제기하면 기판력 저촉을 이유로 후소에 대하여 소각하판결을 하여야 한다고 보는 반복금지설이 대립하고 있다.

(2) 판례

- 전소의 소송물이 동일한 후소에 기판력이 미치는 경우, 전소의 확정판결에서 원고가 승소한 부분에 해당하는 부분은 권리보호이익이 없다(대판 2009.12.24. 2009다64215)고 하여 각하판결을 하고, 전소에서 패소한 경우 청구기각판결의 기판력에 의해 그 내용과 모순되는 판단을 해서는 안 되는 구속력 때문에 청구기각의 판결을 한다(대판 1989.6.27. 87다카2478)고 하여 모순금지설을 취하고 있다.

(3) 검토

- 기판력은 전소 확정판결과 모순·저촉된 판결을 금지하여 법적 안정성을 확보하려는 데 그 취지가 있으므로 모순금지설이 타당하다고 판단된다.

Ⅲ. 기판력의 범위

1. 기판력의 주관적 범위

(1) 당사자

- 처분권주의와 변론주의에 의해 당사자에게만 소송수행의 기회가 부여되므로, 기판력은 당사자에 한하여 미치고 제3자에게는 미치지 아니하는 것이 원칙이다. 그러나 이하에서 보는 것과 같이 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 기판력이 제3자에게 미치는 경우가 있다(민소법 제218조 제1항, 제2항, 제3항).

(2) 당사자와 같이 볼 제3자[민소법 제218조]

① 변론종결 뒤의 승계인

㉮ 의의

- 확정판결의 기판력은 변론을 종결한 뒤의 승계인에 대하여 효력이 있다(민소법 제218조 제1항). 이는 패소 당사자가 소송물이나 계쟁물을 처분하여 승소확정판결을 무력화시키는 것을 막으려는 취지이다.

㉯ 승계요건

㉠ 변론종결 뒤의 승계

- 권리의 이전에 등기를 요하는 경우에는 등기시가 기준이 된다. 판례는 매매를 변론종결 이전에 하였더라도 등기를 변론종결 이후에 마치면 변론종결 뒤의 승계인에 해당하고(대판 2005.11.10. 2005다34867), 가등기를 변론종결 이전에 한 자라도 본등기를 변론종결 후에 마친 경우 변론종결 뒤의 승계인으로 볼 것이나(대판 1992.10.27. 92다10883), 확정판결의 피고 측의 제1차 승계가 이미 변론종결 이전에 있었다 하더라도 비록 제2차 승계가 변론종결 후에 있었다 하더라도 제2차 승계인은 변론종결 뒤의 승계인으로 볼 수 없다(대결 1967.2.23. 67마55)고 한다. 최근 판례는 채권양수인이 소송계속 중의 승계인이라고 주장하며 참가신청을 한 경우에, 채권자로서의 지위의 승계가 소송계속 중에 이루어진 것인지 여부는 채권양도의 합의가 이루어진 때가 아니라 대항요건이 갖추어진 때를 기준으로 판단하는 것과 마찬가지로, 채권양수인이 민사소송법 제218조 제1항에 따라 확정판결의 효력이 미치는 변론종결 뒤의 승계인에 해당하는지 여부 역시 채권양도의 합의가 이루어진 때가 아니라 대항요건이 갖추어진 때를 기준으로 판단하여야 한다(대판 2020.9.3. 2020다210747)고 판시하고 있다.

㉡ 승계인의 범위

ⓐ 소송물의 승계인

(a) 의의

- 소송물 자체의 승계인이란 변론을 종결한 뒤에 당사자로부터 소송물인 실체법상 권리·의무를 승계한 자로 물권적 청구권이든 채권적 청구권이든 제한 없이 변론종결 뒤의 승계인에 해당한다.

(b) 소송물의 승계인에 해당하는 경우

- 소유권확인판결 후 그 소유권을 양수한 자, 대여금채권의 이행판결 후 그 채권을 양수한 자 등이 여기에 해당한다. 승계의 모습은 일반승계(상속, 합병), 특정승계를 가리지 않는다. 따라서 확정판결의 변론종결 후 그 확정판결상의 채무자인 회사를 흡수합병한 존속회사와 확정판결의 변론종결 후 그 확정판결상의 채무자인 회사가 신설합병되어 설립한 회사는 기판력을 받게 된다. 판례는 면책적 채무인수인에 대하여 전소 변론종결 또는 판결선고 후에 채무자의 채무를 소멸시켜 당사자인 채무자의 지위를 승계하는 이른바 면책적 채무인수를 한 자는 변론종결 뒤의 승계인으로서 전소 확정판결의 기판력이 미치게 되므로 원고는 특별한 사정이 없는 한 다시 본소를 제기할 이익이 없다(대판 2016.9.28. 2016다13482)고 판시하고 있다.

(c) 소송물의 승계인에 해당하지 않는 경우

- 중첩적 채무인수는 당사자의 채무는 그대로 존속하며 이와 별개의 채무를 부담하는 것에 불과하므로(대판 2010.1.14. 2009그196), 소송물의 승계인에 해당하지 아니하고 영업양수인은 양도인의 영업상 채무를 변제할 책임이 있어도 변론종결 뒤의 승계인에 해당하지 아니한다(대판 1979.3.13. 78다2330).

ⓑ 계쟁물의 승계인

(a) 의의

- 소송물 자체를 승계한 것이 아니라 다툼의 대상이 된 물건인 계쟁물에 관한 당사자적격을 승계한 자도 이에 포함된다는 것이 학설의 일반적인 태도이다.

(b) 계쟁물 승계의 형태

- 계쟁물 승계의 형태에는 의무자만 바뀌고 청구내용은 같은 경우인 교환적 승계와 의무자가 추가되면서 청구내용도 바뀌는 경우인 추가적 승계가 포함된다. 교환적 승계의 예로는 건물인도를 명하는 판결 확정 후 피고의 점유를 승계받은 자가 있고, 추가적 승계의 예로는 소유권이전등기말소를 명하는 판결 확정 후 등기를 이전받은 자가 있다(대판 1998.11.27. 97다22904).

(c) 계쟁물 승계의 범위

a 문제점

- 소송물의 승계인은 제한 없이 변론종결 뒤의 승계인에 해당하지만 계쟁물 자체의 승계인이 변론종결 뒤의 승계인에 해당하는지 여부에는 견해의 대립이 있다.

b 학설

- 소송물이 물권적 청구권인 경우(소유권에 기한 등기말소청구)에는 대세효가 있으므로 피고로부터 승계한 자는 변론종결 뒤의 승계인에 포함되지만, 소송물이 채권적 청구권인 경우(매매를 원인으로 한 이전등기청구) 피고로부터 승계한 자는 변론종결 뒤의 승계인에 포함되지 아니한다고 하는 구소송물이론과 실체법상 권리와는 무관하게 소송물이 채권적 청구권인 경우에도 계쟁물 승계인이 변론종결 뒤의 승계인에 포함된다고 하는 신소송물이론의 대립이 있다.

c 판례

- 구소송물이론을 취하는 판례는 청구가 소유권에 기한 이전등기말소청구권인 경우 피고로부터 소유권이전등기를 경료받은 자는 승계인으로 보나(대판 1979.2.13. 78다2250), 청구가 매매에 기한 소유권이전등기청구권인 경우 피고로부터 소유권이전등기를 경료받은 자는 승계인에 해당하지 아니한다고 한다(대판 2003.5.13. 2002다64148).

ⓓ 검토

- 소송물이 채권적 청구권인 경우에 변론종결 뒤에 승계한 자는 원고와 양립할 수 있는 권리를 가지고 원고에게 아무런 실체법상의 의무를 부담하지 않는데 이러한 자에게까지 기판력이 미치는 것으로 하는 것은 지나친 기판력의 확장이므로 소송물이 물권적 청구권인 경우에만 기판력을 인정하는 판례의 태도가 타당하다고 판단된다.

ⓒ 승계의 범위에 대한 예외적 판례

(a) 토지인도소송의 사실심 변론종결 후에 그 패소자인 토지소유자로부터 토지를 매수하고 소유권이전등기를 마친 제3자가 확정판결의 변론종결 뒤의 승계인에 해당하는지 여부

- 판례는 토지소유권에 기한 물권적 청구권을 원인으로 하는 토지인도소송의 소송물은 토지소유권이 아니라 그 물권적 청구권인 토지인도청구권이므로 그 소송에서 청구기각된 확정판결의 기판력은 토지인도청구권의 존부 그 자체에만 미치는 것이고 소송물이 되지 아니한 토지소유권의 존부에 관하여는 미치지 아니한다 할 것이므로 그 토지인도소송의 사실심 변론종결 후에 그 패소자인 토지소유자로부터 토지를 매수하고 소유권이전등기를 마침으로써 그 소유권을 승계한 제3자의 토지소유권의 존부에 관하여는 위 확정판결의 기판력이 미치지 않는다 할 것이고 또 이 경우, 위 제3자가 가지게 되는 물권적 청구권인 토지인도청구권은 적법하게 승계한 토지소유권의 일반적 효력으로서 발생된 것이고 위 토지인도소송의 소송물인 패소자의 토지인도청구권을 승계함으로써 가지게 된 것이라고는 할 수 없으므로 위 제3자는 위 확정판결의 변론종결 뒤의 승계인에 해당한다고 할 수도 없다(대판 1984.9.25. 84다카148)고 판시하고 있다.

(b) 토지 소유권에 기한 가등기말소청구소송에서 청구기각된 확정판결의 기판력이 위 소송의 변론종결 후 토지 소유자로부터 근저당권을 취득한 제3자가 근저당권에 기하여 같은 가등기에 대한 말소청구를 하는 경우에 미치는지 여부

- 판례는 확정판결의 기판력은 확정판결의 주문에 포함된 법률적 판단과 동일한 사항이 소송상 문제가 되었을 때 당사자는 이에 저촉되는 주장을 할 수 없고 법원도 이에 저촉되는 판단을 할 수 없는 기속력을 의미하고, 확정판결의 내용대로 실체적 권리관계를 변경하는 실체법적 효력을 갖는 것은 아니다. 토지 소유권에 기한 물권적 청구권을 원인으로 하는 가등기말소청구소송의 소송물은 가등기말소청구권이므로 그 소송에서 청구기각된 확정판결의 기판력은 가등기말소청구권의 부존재 그 자체에만 미치고, 소송물이 되지 않은 토지 소유권의 존부에 관하여는 미치지 않는다. 나아가 위 청구기각된 확정판결로 인하여 토지 소유자가 갖는 토지 소유권의 내용이나 토지 소유권에 기초한 물권적 청구권의 실체적인 내용이 변경・소멸되는 것은 아니다. 위 가등기말소청구소송의 사실심 변론종결 후에 토지 소유자로부터 근저당권을 취득한 제3자는 적법하게 취득한 근저당권의 일반적 효력으로서 물권적 청구권을 갖게 되고, 위 가등기말소청구소송의 소송물인 패소자의 가등기말소청구권을 승계하여 갖는 것이 아니며, 자신이 적법하게 취득한 근저당권에 기한 물권적 청구권을 원인으로 소송상 청구를 하는 것이므로, 위 제3자는 민사소송법 제218조 제1항에서 정한 확정판결의 기판력이 미치는 `변론을 종결한 뒤의 승계인`에 해당하지 않는다. 따라서 토지 소유권에 기한 가등기말소청구소송에서 청구기각된 확정판결의 기판력은 위 소송의 변론종결 후 토지 소유자로부터 근저당권을 취득한 제3자가 근저당권에 기하여 같은 가등기에 대한 말소청구를 하는 경우에는 미치지 않는다(대판 2020.5.14. 2019다261381)고 판시하고 있다.

(c) 판례의 검토

- 생각건대 이 경우 계쟁물의 승계이고, 원고의 청구권은 물권적 청구권이므로 변론종결 뒤의 승계인에 해당한다고 보아야 함에도, 위 판례는 기판력의 주관적 범위를 객관적 범위와 연계시켜 양자를 혼동한 문제점이 있다고 보는 견해가 있으나, 승계인이 적법하게 취득한 소유권(근저당권)으로부터 발생하는 고유의 청구권도 기판력으로부터 보호받을 필요가 있다는 점에서 판례의 결론이 정당하다는 견해가 타당하다고 보인다.

ⓓ 소송물이 다른 후소송을 제기한 전소의 변론종결 뒤의 승계인에게 기판력이 미치는지 여부

- [1] 소송물이 동일하거나 선결문제 또는 모순관계에 의하여 기판력이 미치는 객관적 범위에 해당하지 아니하는 경우에는 전소 판결의 변론종결 후에 당사자로부터 계쟁물 등을 승계한 자가 후소를 제기하더라도 후소에 전소 판결의 기판력이 미치지 아니한다.

- [2] 갑 등이 을을 상대로 건물 등에 관한 소유권이전등기의 말소등기절차 이행을 구하는 소를 제기하여 승소확정판결을 받았는데, 위 판결의 변론종결 후에 을로부터 건물 등의 소유권을 이전받은 병이 갑 등을 상대로 위 건물의 인도 및 차임 상당 부당이득의 반환을 구하는 소를 제기한 사안에서, 전소 판결에서 소송물로 주장된 법률관계는 건물 등에 관한 말소등기청구권의 존부이고 건물 등의 소유권의 존부는 전제가 되는 법률관계에 불과하여 전소 판결의 기판력이 미치지 아니하고, 전소인 말소등기청구권에 대한 판단이 건물인도 등 청구의 소의 선결문제가 되거나 건물인도청구권 등의 존부가 전소의 소송물인 말소등기청구권의 존부와 모순관계에 있다고 볼 수 없어 전소의 기판력이 건물인도 등 청구의 소에 미친다고 할 수 없으며, 이는 병이 전소 판결의 변론종결 후에 을로부터 건물을 매수하여 소유권이전등기를 마쳤더라도 마찬가지이므로, 병이 변론종결 후의 승계인이어서 전소 확정판결의 기판력이 미쳐 건물 등의 소유권을 취득할 수 없다고 본 원심판결에 법리오해 등의 위법이 있다고 한 사례(대판 2014.10.30. 2013다53939).

ⓔ 승계인에게 실체법상 고유의 방어방법이 있는 경우

ⓐ 문제점

- 동산의 선의취득자(민법 제249조), 부동산의 점유취득시효완성자(민법 제245조 제1항), 해제에 의해 보호받는 제3자(민법 제548조 제1항 단서)와 같이 승계인이 고유한 방어방법을 갖고 있는 경우에 승계인에게 기판력이 미치는지 여부에 대해 견해가 대립한다.

ⓑ 학설

- 승계인에게 고유의 방어방법이 있으면 실질적으로 권리의무를 승계하였다고 볼 수 없어 변론종결 뒤 승계인에 해당하지 않으므로 승계인의 항변이 성립할 가능성이 있으면 원고에게 집행문이 부여되지 않고 그가 승계집행문부여의 소를 제기해야 한다고 하는 실질설과 방어방법이 있어도 변론종결 뒤의 승계인에 해당하므로 일단 변론종결 뒤에 승계한 사실만으로 원고에게 승계집행문이 부여되고 그에 대해 승계인이 집행문부여에 대한 이의의 소를 제기해 고유한 방어방법을 증명하면 집행을 막을 수 있다고 하는 형식설이 대립하고 있다.

ⓒ 판례

- 판례는 원고가 명의신탁해지를 원인으로 소유권이전등기를 청구하여 수탁자에게 승소확정판결을 받았으나 수탁자가 제3자에게 처분한 경우, 소유권이전등기를 명하는 확정판결의 변론종결 후에 그 청구목적물을 매수하여 등기를 한 제3자는 변론종결 뒤의 승계인에 해당되지 아니한다(대판 1980.11.25. 80다2217)고 하여 실질설의 태도를 취하고 있다.

ⓓ 검토

- 고유한 방어방법을 가진 승계인에게 집행문부여 이의의 소를 제기하는 부담을 주는 것은 부당하므로 실질설이 타당하다고 판단된다.

ⓕ 효과

- 확정판결의 기판력은 변론종결 뒤의 승계인에게 미친다. 최근 판례는 대금분할을 명한 공유물분할 확정판결의 당사자인 공유자가 공유물분할을 위한 경매를 신청하여 진행된 경매절차에서 공유물 전부에 관하여 매수인에 대한 매각허가결정이 확정되고 매각대금이 완납된 경우, 매수인은 공유물 전부에 대한 소유권을 취득하게 됨에 따라 각 공유지분을 가지고 있던 공유자들은 지분소유권을 상실하게 되고 대금분할을 명한 공유물분할판결의 변론이 종결된 뒤(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결을 선고한 뒤) 해당 공유자의 공유지분에 관하여 소유권이전청구권의 순위보전을 위한 가등기가 마쳐진 경우, 대금분할을 명한

공유물분할 확정판결의 효력은 민사소송법 제218조 제1항이 정한 변론종결 후의 승계인에 해당하는 가등기권자에게 미치므로, 특별한 사정이 없는 한 위 가등기상의 권리는 매수인이 매각대금을 완납함으로써 소멸한다(대판 2021.3.11. 2020다253836)고 판시하고 있다.

② **추정승계인**

㉮ **의의**

- 당사자가 변론종결 전에 소송물을 승계하였어도 그 승계사실을 진술하지 않는 경우에는 변론종결 후에 승계가 이루어진 것으로 추정되어 반증이 없는 한 기판력이 미치게 되는데 이를 추정승계인제도라고 한다.

㉯ **승계를 진술할 자**

- 민사소송법 제218조 제2항의 명문상 승계를 진술할 자를 당사자로 규정하였고 당사자가 아닌 승계인이 무슨 권한으로 변론에서 진술할 수 있을지 의문이므로 승계인이 아니라 피승계인이 승계사실을 진술하여야 할 것이다.

㉰ **승계집행문을 얻는 방법**

- 민사소송법 제218조 제2항에 의하여 원고는 승계사실만 증명하면 피승계인 상대의 승소판결로써 승계인에 대한 승계집행문을 구할 수 있다. 다만, 판례는 기판력의 주관적 범위를 정함에 있어서 당사자가 변론을 종결할 때까지 승계사실을 진술하지 아니한 때에는 변론을 종결한 뒤에 승계한 것으로 추정한다는 민사소송법 제218조 제2항의 취지는, 변론종결 전의 승계를 주장하는 자에게 그 입증책임이 있다는 뜻을 규정하여 변론종결 전의 승계사실이 입증되면 확정판결의 기판력이 그 승계인에게 미치지 아니한다는 것으로 해석되므로, 종전의 확정판결의 기판력의 배제를 원하는 당사자 일방이 변론종결 전에 당사자 지위의 승계가 이루어진 사실을 입증한다면, 종전소송에서 당사자가 그 승계에 관한 진술을 하였는지 여부와 상관없이, 그 승계인이 종전의 확정판결의 기판력이 미치는 변론종결 뒤의 승계인이라는 민사소송법 제218조 제2항의 추정은 깨어진다고 보아야 한다(대판 2005.11.10. 2005다34667)고 판시하고 있다.

㉱ **무변론판결의 경우**

- 무변론판결(민소법 제257조)의 경우에는 그 판결선고 시까지 승계사실을 진술하지 아니하였으면 판결선고 뒤의 승계인으로 추정하도록 규정하고 있다.

③ **청구의 목적물의 소지인**

- 확정판결은 당사자를 위하여 청구의 목적물을 소지한 사람에 대하여 효력을 미친다(민소법 제218조 제1항). 목적물은 특정물인도청구권의 특정물을 말한다. 당사자를 위한 소지인과 변론종결 뒤의 승계인을 위해서 소지한 자도 포함되고 소지의 시기는 변론종결 전후를 불문한다. 다만, 임차인, 질권자 등 자기의 고유한 이익을 위해 소지하는 자는 제외된다. 가장양수인과 명의수탁자는 자기의 고유한 이익을 소지하는 자가 아니므로 이들에게도 유추적용하는 것이 가능하다고 판단된다.

④ **소송담당에서의 권리귀속주체**

㉮ **의의**

- 소송담당자에 대한 확정판결은 권리귀속주체에 대하여도 그 효력이 미친다(민소법 제218조 제3항).

㉯ **채권자대위소송과 기판력**

- 법정소송담당 중 병행형 특히 채권자대위소송의 경우 기판력의 범위에 대하여는 다툼이 있다. 이에 대한 자세한 논의는 채권자대위소송에 대한 주요논점을 참조하라.

㉰ **추심소송과 기판력**

- 판례는 동일한 채권에 대해 복수의 채권자들이 압류·추심명령을 받은 경우 어느 한 채권자가 제기한 추심금소송에서 확정된 판결의 기판력은 그 소송의 변론종결일 이전에 압류·추심명령을 받았던 다른 추심채권자에게 미치지 않는다고 보고 이유를 다음과 같이 판시하고 있다.

- [1] 확정판결의 기판력이 미치는 주관적 범위는 신분관계소송이나 회사관계소송과 같이 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 원칙적으로 당사자, 변론을 종결한 뒤의 승계인 또는 그를 위하여 청구의 목적물을 소지한 사람과 다른 사람을 위하여 원고나 피고가 된 사람이 확정판결을 받은 경우의 그 다른 사람에 국한되고(민사소송법 제218조 제1항, 제3항) 그 밖의 제3자에게는 미치지 않는다. 따라서 추심채권자들이 제기하는 추심금소송의 소송물이 채무자의 제3채무자에 대한 피압류채권의 존부로서 서로 같더라도 소송당사자가 다른 이상 그 확정판결의 기판력이 서로에게 미친다고 할 수 없다.

- [2] 민사집행법 제249조 제3항, 제4항은 추심의 소에서 소를 제기당한 제3채무자는 집행력 있는 정본을 가진 채권자를 공동소송인으로 원고 쪽에 참가하도록 명할 것을 첫 변론기일까지 신청할 수 있고, 그러한 참가명령을 받은 채권자가 소송에 참가하지 않더라도 그 소에 대한 재판의 효력이 미친다고 정한다. 위 규정 역시 참가명령을 받지 않은 채권자에게는 추심금소송의 확정판결의 효력이 미치지 않음을 전제로 참가명령을 통해 판결의 효력이 미치는 범위를 확장할 수 있도록 한 것이다.

- [3] 제3채무자는 추심의 소에서 다른 압류채권자에게 위와 같이 참가명령신청을 하거나 패소한 부분에 대해 변제 또는 집행공탁을 함으로써, 다른 채권자가 계속 자신을 상대로 소를 제기하는 것을 피할 수 있다. 따라서 어느 한 채권자가 제기한 추심금소송에서 확정된 판결의 효력이 다른 채권자에게 미치지 않는다고 해도 제3채무자에게 부당하지 않다. 확정된 화해권고결정에는 재판상 화해와 같은 효력이 있다(민사소송법 제231조). 위에서 본 추심금소송의 확정판결에 관한 법리는 추심채권자가 제3채무자를 상대로 제기한 추심금소송에서 화해권고결정이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 어느 한 채권자가 제기한 추심금소송에서 화해권고결정이 확정되었더라도 화해권고결정의 기판력은 화해권고결정 확정일 전에 압류·추심명령을 받았던 다른 추심채권자에게 미치지 않는다(대판 2020.10.29. 2016다35390).

⑤ **소송탈퇴자**

- 독립당사자참가·참가승계인수승계의 경우 종전당사자는 그 소송에서 탈퇴할 수 있는데 이 경우 참가인과 상대방 당사자 간의 판결의 기판력은 탈퇴자에게도 미친다(민소법 제80조, 제81조, 제82조 제3항).

(3) 일반 제3자에의 확장

- 원칙적으로 일반 제3자에게는 판결의 효력이 미치지 아니한다. 다만, 법률관계의 획일적 해결을 위하여 가사·회사·행정소송에서는 판결효력이 일반 제3자의 법률관계에까지 미치는 것으로 규정하고 있다.

2. 기판력의 객관적 범위

(1) 판결주문에서의 판단

① **기판력의 발생범위**

- 확정판결은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력을 가진다(민소법 제216조 제1항). 따라서 판결이유 중에 판단에 대해서는 기판력이 발생하지 아니한다. 소송판결은 소송요건의 흠에 관한 판단에만, 본안판결의 경우에는 소송물인 권리관계에 대한 판단에만 기판력이 발생한다.

② **기판력이 후소에 작용하는 범위(판례)**

- 전소 확정판결의 기판력은 후소의 소송물이 전소의 소송물과 동일하거나 전소 소송물을 선결문제로 하거나 전소 소송물과 모순관계에 있는 경우에 작용한다.

㉮ **동일관계**

㉠ **의의**

- 동일 소송물의 경우에는 전소의 패소 당사자가 재소한 때에는 전소의 표준시 이전의 사유의 주장을 배척하고 그 다음으로 기판력이 미치지 않는 사유가 있는지 여부를 심리하여 없으면 청구기각의 판결을, 새로운 사유의 주장이 있으면 그 당부를 심리하고 이것을 전소판결의 내용과 합쳐 본안판결을 한다. 한편 전소의 승소 당사자가 재소한 때에는 권리보호이익의 흠결로 소각하판결을 한다. 다만, 판결원본의 멸실 등의 사정이 있는 경우 재소를 받아들여 전소판결과 동일한 판결을 해야 한다.

㉡ 기판력이 작용하는 경우

ⓐ 진정한 등기명의의 회복을 위한 소유권이전등기청구

- 진정한 등기명의의 회복을 위한 소유권이전등기청구는 이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 자가 진정한 등기명의를 회복하기 위한 방법으로 현재의 등기명의인을 상대로 그 등기의 말소를 구하는 것에 갈음하여 허용되는 것인데, 말소등기에 갈음하여 허용되는 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구권과 무효등기의 말소청구권은 어느 것이나 진정한 소유자의 등기명의를 회복하기 위한 것으로서 실질적으로 그 목적이 동일하고, 두 청구권 모두 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 그 법적 근거와 성질이 동일하므로, 비록 전자는 이전등기, 후자는 말소등기의 형식을 취하고 있다고 하더라도 그 소송물은 실질상 동일한 것으로 보아야 하고, 따라서 소유권이전등기말소청구소송에서 패소확정판결을 받았다면 그 기판력은 그 후 제기된 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구소송에도 미친다(대판 2001.9.20. 99다37894[전합]). 판례의 모순금지설에 의하면 전소에서 패소한 원고가 다시 소를 제기하는 것이므로 후소법원은 청구기각판결을 선고해야 한다.

ⓑ 소유권이전등기청구

- 갑이 을에 대하여 전소에서 토지를 대물변제 받아 점유하기 시작하여 취득시효가 완성되었다는 사실을 그 이유로 하여 소유권이전등기절차이행을 구하였다가 배척되었음에도 불구하고 후소에서는 이를 증여받아 점유하기 시작하여 취득시효가 완성되었다고 주장하는 것은 전소의 소송물인 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기청구권의 존부에 관한 공격방법의 하나에 불과한 사실을 후소에서 다시 주장하는 것으로 이는 전소의 사실심 변론종결 전에 주장할 수 있었던 사유임이 명백할 뿐만 아니라, 후소에서 같이 이러한 주장을 하는 것을 허용한다면 위 토지에 관한 취득시효완성을 이유로 하여 을의 위 토지상의 건물철거청구를 거부할 수 있게 된다는 결론에 도달하게 되는 것이니, 갑의 위와 같은 주장은 전소판결의 소송물과 서로 모순관계에 있다고 하지 않을 수 없고, 따라서 전소판결의 기판력에 저촉되어 허용될 수 없다(대판 1995.3.24. 94다46114).

ⓒ 소유권이전등기말소청구

- 동일 당사자 사이의 전・후 두 개의 소유권이전등기말소청구사건에 있어서의 양 소송물은 당해 등기의 말소청구권이고, 그 동일성 식별의 표준이 되는 청구원인 즉 말소등기청구권의 발생원인은 당해 등기원인의 무효에 국한되므로 전소의 변론종결 전까지 주장할 수 있었던 무효사유는 그것이 무권대리행위, 불공정한 법률행위이거나 또는 통모허위표시에 의한 매매무효를 이유로 하거나 간에 다 같이 청구원인인 등기원인이 무효임을 뒷받침하는 이른바 독립된 공격방어방법에 불과하여 서로 별개의 청구원인을 구성하는 것이 아니므로 기판력의 표준시인 전소의 변론종결 전에 발생한 사유로서 전소에서 주장하지 아니하여 패소한 경우라도 그 사유는 전소의 확정판결의 기판력에 의하여 후소에서 주장하여 확정판결의 내용을 다툴 수 없다(대판 1982.12.14. 82다카148).

ⓓ 부당이득반환청구

- 계약해제의 효과로서의 원상회복은 부당이득에 관한 특별규정의 성격을 가지는 것이고, 부당이득반환청구에서 법률상의 원인 없는 사유를 계약의 불성립, 취소, 무효, 해제 등으로 주장하는 것은 공격방법에 지나지 아니하므로 그중 어느 사유를 주장하여 패소한 경우에 다른 사유를 주장하여 청구하는 것은 기판력에 저촉되어 허용될 수 없다 할 것이다(대판 2000.5.12. 2000다5978).

ⓔ 토지거래허가구역 내에서의 소유권이전등기청구

- 갑이 을과 토지거래허가구역 내 토지를 매수한 계약을 체결한 후 을을 상대로 소유권이전등기청구 등의 소를 제기하여 토지거래허가신청절차 이행 청구는 인용하고 소유권이전등기절차 이행청구는 기각한 판결이 확정되었는데, 변론종결 전에 위 토지가 토지거래허가구역에서 해제되었음에도 갑이 이를 주장하지 아니하여 전소법원은 위 토지가 허가구역 내에 위치함을 전제로 판결하였고, 그 후 갑이 위 토지가 토지거래허가구역에서 해제되었음을 들어 을을 상대로 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소를 제기한 경우, 후소가 전소 확정판결의 기판력에 반한다(대판 2014.3.27. 2011다79968).

㉢ 기판력이 작용하지 않는 경우

ⓐ 대물변제예약에 기한 소유권이전등기청구권과 매매계약에 기한 소유권이전등기청구권의 소송물의 동일성 여부

- 대물변제예약에 기한 소유권이전등기청구권과 매매계약에 기한 소유권이전등기청구권은 그 소송물이 서로 다르므로 동일한 계약관계에 대하여 그 계약의 법적 성질을 대물변제의 예약이라고 하면서도 새로운 매매계약이 성립되었음을 인정하여 매매를 원인으로 한 소유권이전등기 절차를 이행할 의무가 있다고 하는 것은 위법하다(대판 1997.4.25. 96다32133).

ⓑ 1필의 토지의 일부인 특정 부분에 대한 소유권이전등기청구가 기각된 후 그 1필 전체 토지 중 일정 지분에 대한 소유권이전등기를 청구하는 경우

- 갑이 을로부터 1필의 토지의 일부를 특정하여 매수하였다고 주장하면서 을을 상대로 그 부분에 대한 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 목적물이 갑의 주장과 같은 부분으로 특정되었다고 볼 증거가 없다는 이유로 청구가 기각되었고, 이에 대한 갑의 항소・상고가 모두 기각됨으로써 판결이 확정되자, 다시 을을 상대로 그 전체 토지 중 일정 지분을 매수하였다고 주장하면서 그 지분에 대한 소유권이전등기를 구하는 소를 제기한 경우, 전소와 후소는 그 각 청구취지를 달리하여 소송물이 동일하다고 볼 수 없으므로, 전소의 기판력은 후소에 미칠 수 없다(대판 1995.4.25. 94다17956[전합]).

ⓒ 시효중단을 위한 후소절차에서 전소의 변론종결 후의 채권소멸사유로 항변할 수 있는지 여부(적극)

- [1] 확정된 승소판결에는 기판력이 있으므로 승소 확정판결을 받은 당사자가 전소의 상대방을 상대로 다시 승소 확정판결의 전소와 동일한 청구의 소를 제기하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 후소는 권리보호의 이익이 없어 부적법하다. 하지만 예외적으로 확정판결에 의한 채권의 소멸시효기간인 10년의 경과가 임박한 경우에는 그 시효중단을 위한 소는 소의 이익이 있다. 이는 승소판결이 확정된 후 그 채권의 소멸시효기간인 10년의 경과가 임박하지 않은 상태에서 굳이 다시 동일한 소를 제기하는 것은 확정판결의 기판력에 비추어 권리보호의 이익을 인정할 수 없으나, 그 기간의 경과가 임박한 경우에는 시효중단을 위한 필요성이 있으므로 후소를 제기할 소의 이익을 인정하는 것이다.

- [2] 한편 시효중단을 위한 후소의 판결은 전소의 승소 확정판결의 내용에 저촉되어서는 아니 되므로, 후소 법원으로서는 그 확정된 권리를 주장할 수 있는 모든 요건이 구비되어 있는지에 관하여 다시 심리할 수 없으나, 위 후소 판결의 기판력은 후소의 변론종결 시를 기준으로 발생하므로, 전소의 변론종결 후에 발생한 변제, 상계, 면제 등과 같은 채권소멸사유는 후소의 심리대상이 된다. 따라서 채무자인 피고는 후소 절차에서 위와 같은 사유를 들어 항변할 수 있고 심리 결과 그 주장이 인정되면 법원은 원고의 청구를 기각하여야 한다. 이는 채권의 소멸시효 중 하나인 소멸시효 완성의 경우에도 마찬가지이다. 이처럼 판결이 확정된 채권의 소멸시효기간의 경과가 임박하였는지 여부에 따라 시효중단을 위한 후소의 권리보호이익을 달리 보는 취지와 채권의 소멸시효 완성이 갖는 효과 등을 고려해 보면, 시효중단을 위한 후소를 심리하는 법원으로서는 전소 판결이 확정된 후 소멸시효가 중단된 적이 있어 그 중단사유가 종료한 때로부터 새로이 진행된 소멸시효기간의 경과가 임박하지 않아 시효중단을 위한 재소의 이익을 인정할 수 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 후소가 전소 판결이 확정된 후 10년이 지나 제기되었다 하더라도 곧바로 소의 이익이 없다고 하여 소를 각하해서는 아니 되고, 채무자인 피고의 항변에 따라 원고의 채권이 소멸시효 완성으로 소멸하였는지에 관한 본안판단을 하여야 한다(대판 2019.1.17. 2018다24349).

- [3] 시효중단을 위한 후소절차에서 전소의 권리관계를 다툴 수 있는지 여부(소극)(위 판례(ⓒ)와 구분) : 시효중단 등 특별한 사정이 있어 예외적으로 확정된 승소판결과 동일한 소송물에 기한 신소가 허용되는 경우라 하더라도 신소의 판결이 전소의 승소 확정판결의 내용에 저촉되어서는 아니 되므로, 후소 법원으로서는 그 확정된 권리를 주장할 수 있는 요건이 구비되어 있는지에 관하여 다시 심리할 수 없다. 따라서 피고가 후소에서 전소의 확정된 권리관계를

다투기 위하여는 먼저 전소의 승소확정판결에 대하여 적법한 추완항소를 제기함으로써 그 기판력을 소멸시켜야 할 것인데, 이는 전소의 소장부본과 판결정본 등이 공시송달의 방법에 의하여 송달되어 피고가 그 책임질 수 없는 사유로 전소에 응소할 수 없었던 경우라고 하여 달리 볼 것이 아니다(대판 2013.4.11. 2012다111340).

ⓓ 시효중단을 위한 새로운 방식의 확인소송

- 종래 대법원은 시효중단사유로서 재판상의 청구에 관하여 반드시 권리 자체의 이행청구나 확인청구로 제한하지 않을 뿐만 아니라, 권리자가 재판상 그 권리를 주장하여 권리 위에 잠자는 것이 아님을 표명한 것으로 볼 수 있는 때에는 널리 시효중단사유로서 재판상의 청구에 해당하는 것으로 해석해 왔다. 이와 같은 법리는 이미 승소 확정판결을 받은 채권자가 그 판결상 채권의 시효중단을 위해 후소를 제기하는 경우에도 동일하게 적용되므로, 채권자가 전소로 이행청구를 하여 승소 확정판결을 받은 후 그 채권의 시효중단을 위한 후소를 제기하는 경우, 후소의 형태로서 항상 전소와 동일한 이행청구만이 시효중단사유인 `재판상의 청구`에 해당한다고 볼 수는 없다. 시효중단을 위한 이행소송은 다양한 문제를 야기한다. 그와 같은 문제들의 근본적인 원인은 시효중단을 위한 후소의 형태로 전소와 소송물이 동일한 이행소송이 제기되면서 채권자가 실제로 의도하지도 않은 청구권의 존부에 관한 실체 심리를 진행하는 데에 있다. 채무자는 그와 같은 후소에서 전소 판결에 대한 청구이의사유를 조기에 제출하도록 강요되고 법원은 불필요한 심리를 해야 한다. 채무자는 이중집행의 위험에 노출되고, 실질적인 채권의 관리・보전비용을 추가로 부담하게 되며 그 금액도 매우 많은 편이다. 채권자 또한 자신이 제기한 후소의 적법성이 10년의 경과가 임박하였는지 여부라는 불명확한 기준에 의해 좌우되는 불안정한 지위에 놓이게 된다. 위와 같은 종래 실무의 문제점을 해결하기 위해서, 시효중단을 위한 후소로서 이행소송 외에 전소 판결로 확정된 채권의 시효를 중단시키기 위한 조치, 즉 `재판상의 청구`가 있다는 점에 대하여만 확인을 구하는 형태의 `새로운 방식의 확인소송`이 허용되고, 채권자는 두 가지 형태의 소송 중 자신의 상황과 필요에 보다 적합한 것을 선택하여 제기할 수 있다고 보아야 한다(대판 2018.10.18. 2015다232316[전합]).

ⓔ 물건 점유자를 상대로 한 물건의 인도판결이 확정된 경우

- 점유자는 인도판결 상대방에 대하여 소송에서 더 이상 물건에 대한 인도청구권의 존부를 다툴 수 없고 인도소송의 사실심 변론종결 시까지 주장할 수 있었던 정당한 점유권원을 내세워 물건의 인도를 거절할 수 없다. 그러나 의무 이행을 명하는 판결의 효력이 실체적 법률관계에 영향을 미치는 것은 아니므로, 점유자가 그 인도판결의 효력으로 판결 상대방에게 물건을 인도해야 할 실체적 의무가 생긴다거나 정당한 점유권원이 소멸하여 그때부터 그 물건에 대한 점유가 위법하게 되는 것은 아니다. 나아가 물건을 점유하는 자를 상대로 하여 물건의 인도를 명하는 판결이 확정되더라도 그 판결의 효력은 이들 물건에 대한 인도청구권의 존부에만 미치고, 인도판결의 기판력이 이들 물건에 대한 불법점유를 원인으로 한 손해배상청구 소송에 미치지 않는다(대판 2019.10.17. 2014다46778).

㉣ 선결관계

㉠ 의의

- 선결관계의 경우에는 선결문제인 한도에서 전소의 기판력 있는 판단에 구속되어 이를 전제로 하여 본안판결을 하여야 할 뿐 소각하판결을 하여서는 안 된다. 또한 전소의 기판력 있는 판단이 후소의 항변사유가 될 때에도 기판력이 작용한다(대판 1987.6.9. 86다카2756).

㉡ 기판력이 작용하는 경우

ⓐ 소유권이전등기청구의 소를 제기하여 패소판결이 확정된 후 다시 이행의무가 존재함을 이유로 이행불능을 원인으로 하는 손해배상청구의 소를 제기하는 경우

- 갑・을 간의 이전등기이행청구에 대하여 이행의무 없다 하여 기각판결이 확정된 뒤에 다시 을에게 그러한 이행의무 있다는 주장은 기판력에 저촉되므로 을에게 그와 같은 의무 있음을 전제로 그 이행불능을 원인으로 을에게 손해배상청구를 하는 것은 허용되지 아니한다(대판 1967.8.29. 67다1179).

ⓑ 원금지급청구에 대하여 패소판결이 확정된 이후 다시 원금이 존재함을 이유로 전소 변론종결 이후의 지연이자 부분의 청구를 하는 경우

- 확정판결의 기판력은 사실심의 최종변론종결 당시의 권리관계를 확정하는 것이므로, 원고의 청구 중 확정판결의 사실심 변론종결 시 후의 이행지연으로 인한 손해배상(이자) 청구 부분은 그 선결문제로서 확정판결에 저촉되는 금원에 대한 피고의 지급의무의 존재를 주장하게 되어 논리상 확정판결의 기판력의 효과를 받게 되는 것이라고 할 것이나 그 외의 부분(변론종결 당시까지의 분)의 청구는 확정판결의 기판력의 효과를 받지 않는다(대판 1976.12.14. 76다1488).

ⓒ 채권자대위소송에서 소각하판결이 확정된 후 민법 제213조 단서의 항변을 하는 경우

- 갑이 을을 대위하여 병을 상대로 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기 소송을 제기하였다가 을을 대위할 피보전채권의 부존재를 이유로 소각하판결을 선고받고 확정된 후 병이 제기한 토지인도 소송에서 갑이 다시 위와 같은 권리가 있음을 항변사유로서 주장하는 것은 기판력에 저촉되어 허용될 수 없다(대판 2001.1.16. 2000다41349).

ⓓ 원고가 소유권확인청구를 하여 승소확정판결을 받은 뒤에 같은 피고를 상대로 소유권에 기한 물권적 청구권에 기한 소를 제기하는 경우

- 환지처분의 공고가 있는 경우에는 환지계획에서 정하여진 환지는 환지처분의 공고가 있는 날의 다음 날부터 종전의 토지로 보게 되어 종전의 토지에 대하여 존재하던 소유권 기타 권리관계는 동일성을 유지하면서 환지에 그대로 옮겨지게 되는 것이므로 소유자를 달리한 수필지의 토지에 대하여 적법하게 한 필지의 환지가 지정된 경우에는 종전의 수필지의 소유권은 한 필지에 그대로 이행되는 결과 특별한 사정이 없으면 종전의 토지에 상응하는 비율에 따라서 종전의 소유자들은 환지에 대하여 공유지분을 취득하게 되는 것이므로, 환지처분 전 종전 토지에 관한 소유권확인의 소와 환지처분 후의 새로운 환지 중 종전의 토지에 상응하는 비율의 해당 공유지분에 관한 소유권확인의 소는 서로 동일한 소송물이라 할 것이다(대판 1994.12.27. 94다34684).

ⓔ 기판력이 작용하지 않는 경우 - 채무부존재확인의 확정판결이 있는 후 그 채무부존재를 원인으로 등기말소청구를 하는 경우

- 채권채무의 존부에 관한 청구와 그 채권・채무관계를 원인으로 한 등기의 말소청구권의 존부는 별개의 소송물이므로 채무부존재확인의 확정판결의 기판력은 그 채무부존재를 원인으로 하는 등기말소청구소송에 미칠 수 없다(대판 1980.9.9. 80다1020).

㉤ 모순관계

㉠ 의의

- 모순된 반대관계에서는 전소에서 확정된 소송물과 후소의 소송물이 서로 모순관계로 동일성이 있으므로 동일관계의 경우에 기판력이 미치는 경우와 마찬가지로 취급된다.

㉡ 기판력이 작용하는 경우

ⓐ 원고가 매매의 유효를 원인으로 소유권이전등기청구의 소를 제기하여 승소확정된 이후 피고가 위 매매가 무효임을 주장하면서 등기의 말소를 구하는 경우

- 확정판결의 기판력은 소송물로 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단의 결론 자체에만 미치고 그 전제가 되는 법률관계의 존부에까지 미치는 것은 아니어서, 가등기에 기한 소유권이전등기절차의 이행을 명한 전소 판결의 기판력은 소송물인 소유권이전등기청구권의 존부에만 미치고 그 등기청구권의 원인이 되는 채권계약의 존부나 판결이유 중에 설시되었을 뿐인 가등기의 효력 유무에 관한 판단에는 미치지 아니하고, 따라서 만일 후소로써 위 가등기에 기한 소유권이전등기의 말소를 청구한다면 이는 1물1권주의의 원칙에 비추어 볼 때 전소에서 확정된 소유권이전등기청구권을 부인하고 그와 모순되는 정반대의 사항을 소송물로 삼은 경우에 해당하여 전소 판결의 기판력에 저촉된다고 할 것이지만, 이와 달리 위 가등기만의 말소를 청구하는 것은, 전소에서 판단의 전제가 되었을 뿐이고 그로써 아직 확정되지는 아니한 법률관계를 다투는 것에 불과하여 전소 판결의 기판력에 저촉된다고 볼 수 없다(대판 1995.3.24. 93다52488).

ⓑ 원고가 매매의 무효를 원인으로 소유권이전등기말소청구의 소를 제기하여 승소확정된 이후 피고가 위 매매가 유효임을 주장하면서 소유권이전등기를 구하는 경우

- 전후소의 당사자가 동일하므로 주관적 범위에서 기판력이 작용하고, 전소의 주문판단은 원고에게 말소등기청구권이 존재한다는 것인데 후소의 청구취지는 전소에서 인정된 말소등기청구권 자체를 부인하는 것이고, 청구원인 역시 전소에서 인정된 매매가 무효라는 사실을 부인하는 것이므로 모순관계에 해당하여 객관적 범위에서 작용하며 피고가 진술한 매매계약이 유효하다는 주장은 전소 변론종결 전에 주장할 수 있었던 방어방법이므로 시적 범위에서 차단된다. 따라서 판례의 모순금지설에 의하면 후소 법원은 청구기각판결을 하게 된다.

ⓒ 제3자가 소유자를 상대로 확정판결을 받아 소유권이전등기를 경료한 후 종전의 소유권이전등기청구권을 가지는 자가 소유자를 대위하여 제3자 명의의 소유권이전등기가 원인무효임을 내세워 그 등기의 말소를 구하는 경우

- 부동산의 소유자에 대하여 소유권이전등기를 청구할 지위에 있기는 하지만 아직 그 소유권이전등기를 경료하지 않은 상태에서, 제3자가 부동산의 소유자를 상대로 그 부동산에 관한 소유권이전등기절차 이행의 확정판결을 받아 소유권이전등기를 경료한 경우, 그 확정판결이 당연무효이거나 재심의 소에 의하여 취소되지 않는 한, 종전의 소유권이전등기청구권을 가지는 자가 부동산의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 부동산의 소유자를 대위하여 제3자 명의의 소유권이전등기가 원인무효임을 내세워 그 등기의 말소를 구하는 것은 확정판결의 기판력에 저촉되므로 허용될 수 없다(대판 1999.2.24. 97다46955).

ⓒ 기판력이 작용하지 않는 경우

ⓐ 조합이 적법한 양도담보권자라는 전제에서 농지인도청구 등을 인용한 전소의 확정판결 후 조합이 양도담보권자가 될 수 없다 하여 소유권이전등기의 말소를 청구한 경우

- 채무를 담보하기 위하여 채권자 명의로 농지의 소유권이전등기를 하는 경우에도 농지개혁법상의 농지소유에 필요한 모든 요건을 구비하여야 하므로 농가 아닌 자에게 농지를 담보로 하여 경료된 소유권이전등기는 원인무효이다. 농지개량조합이 원고가 되어 위 조합이 농지에 관한 적법한 양도담보권자라는 전제에서 농지인도청구 등을 인용한 전소의 확정판결과 전소의 피고가 원고가 되어 위 조합이 이 사건 농지 부분에 대하여 양도담보권자가 될 수 없다 하여 소유권이전등기의 말소를 청구한 후소와는 그 소송물이 상이하므로 기판력에 저촉하지 아니한다(대판 1979.2.13. 78다58[전합]).

ⓑ 전·후소의 소송물의 각 전제가 되는 법률관계가 모순되는 경우

- [1] 전에 제기된 소와 후에 제기된 소의 소송물이 동일하지 않다고 하더라도, 후에 제기된 소의 소송물이 전에 제기된 소에서 확정된 법률관계와 모순되는 정반대의 사항을 소송물로 삼았다면 이러한 경우에는 전번 판결의 기판력이 후에 제기된 소에 미치는 것이지만, 확정판결의 기판력은 소송물로 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단의 결론에만 미치고 그 전제가 되는 법률관계의 존부에까지 미치는 것이 아니므로, 전의 소송에서 확정된 법률관계란 확정판결의 기판력이 미치는 법률관계를 의미하는 것이지 그 전제가 되는 법률관계까지 의미하는 것은 아니다.

- [2] 매매계약의 무효 또는 해제를 원인으로 한 매매대금반환청구에 대한 인낙조서의 기판력은 그 매매대금반환청구권의 존부에 관하여만 발생할 뿐, 그 전제가 되는 선결적 법률관계인 매매계약의 무효 또는 해제에까지 발생하는 것은 아니므로 소유권이전등기청구권의 존부를 소송물로 하는 후소는 전소에서 확정된 법률관계와 정반대의 모순되는 사항을 소송물로 하는 것이라 할 수 없으며, 기판력이 발생하지 않는 전소와 후소의 소송물의 각 전제가 되는 법률관계가 매매계약의 유효 또는 무효로서 서로 모순된다고 하여 전소에서의 인낙조서의 기판력이 후소에 미친다고 할 수 없다(대판 2005.12.23. 2004다55698).
청구취지와 청구원인이 각기 상이한 경우: 전소의 소송물은 부동산에 대한 소유권 확인과 소유권보존등기에 대한 말소등기청구권의 존부였던 것임에 반하여 후소는 비록 동일 부동산에 관한 것이기는 하지만 점유취득시효 완성을 원인으로 하는 소유권이전등기청구권의 존부에 관한 것인 경우, 위 전후의 양 소는 그 청구취지와 청구원인이 각기 상이하여 서로 모순·저촉된다고 할 수 없으므로 전소판결의 기판력이 후소에 미친다고 할 수 없다(대판 1997.11.14. 97다32239).

(2) 판결이유 중의 판단

① 사실

- 판결이유 중에 판단된 사실은 기판력이 발생하지 아니한다. 예를 들면 말소등기판결 이유 중에서 판단된 피고가 무권대리인으로부터 매수했다는 사실인정, 손해배상판결의 이유 중에 판단된 고의·과실·인과관계에는 기판력이 발생하지 아니한다.

② 선결적 법률관계

㉮ 선결적 법률관계에 기판력 인정 여부

㉠ 문제점

- 소송물 판단의 전제가 되는 선결적 법률관계의 판단에는 기판력이 발생하지 아니하므로 기판력이 미치게 하려면 중간확인의 소 또는 별소를 제기하여 선결적 법률관계를 소송물로 삼아야 한다. 그러나 판결이유 중의 판단에 구속력이 없으면 전·후소의 판결이 모순될 우려가 있는 경우가 있어 이를 시정하기 위해 기판력 등을 인정할지 여부가 문제된다.

㉡ 학설

- 당사자가 주요한 쟁점으로 다투고 법원이 심리해 내린 쟁점에 대한 판결이유 중의 판단에 쟁점효가 발생하므로 구속력을 인정하는 견해와 민사소송법 제264조에서 선결적 법률관계에 대해 기판력을 얻기 위해 따로 중간확인의 소를 규정하고 있다는 점을 들어 판결이유 중의 판단에 구속력을 부정하는 견해가 대립하고 있다.

㉢ 판례

- 판례는 민사재판에 있어서는 다른 민사사건 등의 판결에서 인정된 사실에 구속받는 것이 아니라 할지라도 이미 확정된 관련 민사사건에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 되므로, 합리적인 이유 설시 없이 이를 배척할 수 없고, 특히 전후 두 개의 민사소송이 당사자가 같고 분쟁의 기초가 된 사실도 같으나 다만 소송물이 달라 기판력에 저촉되지 아니한 결과 새로운 청구를 할 수 있는 경우에 있어서는 더욱 그러하다(대판 1995.6.29. 94다47292)고 하였고, 최근 판례도 같은 취지에서 형사판결도 민사재판에서는 형사재판의 사실인정에 구속을 받는 것이 아니라고 하더라도 동일한 사실관계에 관하여 이미 확정된 형사판결이 유죄로 인정한 사실은 유력한 증거자료가 된다고 할 것이므로 민사재판에서 제출된 다른 증거들에 비추어 형사재판의 사실판단을 채용하기 어렵다 고 인정되는 특별한 사정이 없는 한 이와 반대되는 사실을 인정할 수 없다(대판 2023.6.15. 2022다297632)고 하여 증명력설을 취하고 있다.

㉣ 검토

- 생각건대 판결이유 중의 판단에 구속력을 인정하게 되면 민사소송법 제216조에 반하게 되는 문제가 있고, 법원이 판결이유에 심리를 치중하게 되어 소송지연의 원인이 될 수 있어 민사재판에서 이와 관련된 다른 민·형사사건에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되므로 후소법원은 합리적인 이유 설시 없이 이를 배척할 수 없다고 보아 판결의 모순·저촉을 피하는 것이 타당하다고 판단된다(증명력설).

㉯ 선결적 법률관계 관련 판례

㉠ 말소등기청구소송에서 선결적 법률관계인 소유권에 관한 판단

- 확정판결의 기판력은 소송물로 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단의 결론에만 미치고 그 전제가 되는 법률관계의 존부에까지 미치는 것은 아니므로, 계쟁 부동산에 관한 피고 명의의 소유권이전등기가 원인무효라는 이유로 원고가 피고를 상대로 그 등기의 말소를 구하는 소송을 제기하였다가 청구기각의

판결을 선고받아 확정되었다고 하더라도, 그 확정판결의 기판력은 소송물로 주장된 말소등기청구권이나 이전등기청구권의 존부에만 미치는 것이지 그 기본이 된 소유권 자체의 존부에는 미치지 아니하고, 따라서 원고가 비록 위 확정판결의 기판력으로 인하여 계쟁 부동산에 관한 등기부상의 소유 명의를 회복할 방법은 없게 되었다고 하더라도 그 소유권이 원고에게 없음이 확정된 것은 아닐 뿐만 아니라, 등기부상 소유자로 등기되어 있지 않다고 하여 소유권을 행사하는 것이 전혀 불가능한 것도 아닌 이상, 원고로서는 그의 소유권을 부인하는 피고에 대하여 계쟁 부동산이 원고의 소유라는 확인을 구할 법률상 이익이 있으며, 이러한 법률상의 이익이 있는 이상에는 특별한 사정이 없는 한 소유권확인 청구의 소 제기 자체가 신의칙에 반하는 것이라고 단정할 수 없는 것이다(대판 2002. 9.24. 2002다11847).

㉡ 건물철거 및 토지인도청구소송에서 선결적 법률관계인 소유권에 관한 판단

- 확정판결의 기판력은 그 판결의 주문에 포함된 것, 즉 소송물로 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단의 결론 그 자체에만 생기는 것이고, 판결이유에 설시된 그 전제가 되는 법률관계의 존부에까지 미치는 것은 아니고, 건물철거 및 토지인도청구권을 소송물로 하는 소송은 소유권 자체의 확정이 아니라 건물철거청구권 및 토지인도청구권의 존부만을 목적으로 할 따름이므로 그 소송에서 부동산의 권리귀속에 관한 판단이 있었다고 하더라도 그 기판력은 판결주문에 표시된 건물철거청구권 및 토지인도청구권에 국한되고 판결이유 중의 부동산 권리귀속에 관한 판단 부분에까지 미치지는 아니한다(대판 2010.12.23. 2010다58889).

㉢ 매매대금반환청구소송에서 선결적 법률관계인 매매계약의 무효에 관한 판단

- 매매계약의 무효 또는 해제를 원인으로 한 매매대금반환청구에 대한 인낙조서의 기판력은 그 매매대금반환청구권의 존부에 관하여만 발생할 뿐, 그 전제가 되는 선결적 법률관계인 매매계약의 무효 또는 해제에까지 발생하는 것은 아니므로 소유권이전등기청구권의 존부를 소송물로 하는 후소는 전소에서 확정된 법률관계와 정반대의 모순되는 사항을 소송물로 하는 것이라 할 수 없으며, 기판력이 발생하지 않는 전소와 후소의 소송물의 각 전제가 되는 법률관계가 매매계약의 유효 또는 무효로 서로 모순된다고 하여 전소에서의 인낙조서의 기판력이 후소에 미친다고 할 수 없다(대판 2005.12.23. 2004다55698).

㉣ 임대차보증금의 지급을 명하는 확정판결의 기판력이 임대차보증금에 의해 담보되는 연체차임채무 등의 부존재에도 미치는지 여부

- 임차인이 임대차계약 종료 이후에도 동시이행의 항변권을 행사하는 방법으로 목적물의 반환을 거부하기 위하여 임차건물부분을 계속 점유하기는 하였으나 이를 본래의 임대차계약상의 목적에 따라 사용·수익하지 아니하여 실질적인 이득을 얻은 바 없는 경우에는 그로 인하여 임대인에게 손해가 발생하였다 하더라도 임차인의 부당이득반환의무는 성립되지 아니한다 할 것이다. 확정판결은 주문에 포함한 것에 한하여 기판력이 있는 것이므로, 확정판결의 기판력은 소송물로 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단의 결론 자체에만 미치고 그 전제가 되는 법률관계의 존부에까지 미치는 것은 아니라고 할 것인바, 임대차보증금은 임대차 종료 후에 임차인이 임차목적물을 임대인에게 반환할 때 연체차임 등 모든 피담보채무를 공제한 잔액이 있을 것을 조건으로 하여 그 잔액에 대하여서만 임차인의 반환청구권이 발생하고, 또 임대차보증금의 지급을 명하는 판결이 확정되면 변론종결 전의 사유를 들어 당사자 사이에 수수된 임대차보증금의 수액 자체를 다투는 것은 허용되지 아니한다 하더라도, 임대차보증금 반환청구권 행사의 전제가 되는 연체차임 등 피담보채무의 부존재에 대하여 기판력이 작용하는 것은 아니다(대판 2001.2.9. 2000다61398).

③ 항변

㉮ 일반항변

- 항변은 소송물이 아니기 때문에 판결이유 중에 판단되는 법정지상권 항변, 동시이행의 항변 등에는 기판력이 발생하지 아니한다. 상환이행을 명하는 확정판결의 기판력은 소송물에 대여금 또는 청산금 지급이 상환조건으로 붙어 있다는 점에 미치는 데 불과하고, 상환이행을 명한 반대채권의 존부나 그 수액에 기판력이 미치지 않는다(대판 1996.7.12. 96다19017).

㉯ 상계항변

㉠ 의의

- 판결이유 중의 판단임에도 불구하고 상계 주장에 관한 법원의 판단에 기판력을 인정한 취지는, 만일 이에 대하여 기판력을 인정하지 않는다면, 원고의 청구권의 존부에 대한 분쟁이 나중에 다른 소송으로 제기되는 반대채권의 존부에 대한 분쟁으로 변형됨으로써 상계 주장의 상대방은 상계를 주장한 자가 반대채권을 이중으로 행사하는 것에 의하여 불이익을 입을 수 있게 될 뿐만 아니라, 상계 주장에 대한 판단을 전제로 이루어진 원고의 청구권의 존부에 대한 전소의 판결이 결과적으로 무의미하게 될 우려가 있게 되므로, 이를 막기 위함이다(대판 2018.8.30. 2016다46338).

㉡ 기판력의 발생요건

ⓐ 자동채권에 대한 요건

- 상계항변에 관한 판단에 기판력이 발생하려면 자동채권이 판단되어야 하고, 실기하여 각하된 경우, 상계부적상으로 배척된 경우 등에는 기판력이 발생하지 아니한다.

ⓑ 수동채권에 대한 요건

- 상계 주장에 관한 판단에 기판력이 인정되는 경우는, 상계 주장의 대상이 된 수동채권이 소송물로서 심판되는 소구채권이거나 그와 실질적으로 동일하다고 보이는 경우(가령 원고가 상계를 주장하면서 청구이의의 소송을 제기하는 경우 등)로서 상계를 주장한 반대채권과 그 수동채권을 기판력의 관점에서 동일하게 취급하여야 할 필요성이 인정되는 경우를 말한다고 봄이 상당하므로 만일 상계 주장의 대상이 된 수동채권이 동시이행항변에 행사된 채권일 경우에는 그러한 상계 주장에 대한 판단에는 기판력이 발생하지 않는다고 보아야 할 것인바, 위와 같이 해석하지 않을 경우 동시이행항변이 상대방의 상계의 재항변에 의하여 배척된 경우에 그 동시이행항변에 행사된 채권을 나중에 소송상 행사할 수 없게 되어 민사소송법 제216조가 예정하고 있는 것과 달리 동시이행항변에 행사된 채권의 존부나 범위에 관한 판결 이유 중의 판단에 기판력이 미치는 결과에 이르기 때문이다(대판 2005.7.22. 2004다17207).

ⓒ 단독행위로서의 상계

- 여기의 상계는 단독행위로서의 상계를 의미하므로 피고가 상계항변을 한 것이 아니라 상계하여 정산하기로 합의하였다고 항변하는 경우 기판력이 발생하지 아니한다는 것이 판례이다(대판 2014.4.10. 2013다54390).

㉢ 기판력의 발생범위

ⓐ 상계항변을 배척한 경우

- 반대채권의 부존재에 기판력이 발생한다. 판례는 확정된 판결의 이유 부분의 논리구조상 법원이 당해 소송의 소송물인 수동채권의 전부 또는 일부의 존재를 인정하는 판단을 한 다음 피고의 상계항변에 대한 판단으로 나아가 피고가 주장한 반대채권의 존재를 인정하지 않고 상계항변을 배척하는 판단을 한 경우에, 그와 같이 반대채권이 부존재한다는 판결이유 중의 판단의 기판력은 특별한 사정이 없는 한 `법원이 반대채권의 존재를 인정하였더라면 상계에 관한 실질적 판단으로 나아가 수동채권의 상계적상일까지의 원리금과 대등액에서 소멸하는 것으로 판단할 수 있었던 반대채권의 원리금 액수`의 범위에서 발생한다고 보아야 한다. 그리고 이러한 법리는 피고가 상계항변으로 주장하는 반대채권의 액수가 소송물로서 심판되는 소구채권의 액수보다 더 큰 경우에도 마찬가지로 적용된다(대판 2018.8.30. 2016다46338)고 한다.

ⓑ 상계항변을 인용한 경우

- 원고의 소구채권과 피고의 반대채권이 모두 존재하고 그것이 상계에 의해 소멸하였다는 판단에 기판력이 미친다는 견해와 현재의 법률관계로서 자동채권이 존재하지 않는다는 점에 기판력이 발생한다는 견해가 대립하고 있으나 민사소송법 제216조 제2항의 조문의 해석에 충실한 전자의 견해가 타당하다.

ⓒ 수개의 반대채권 중 일부는 인용, 나머지는 배척한 경우

- 피고가 상계항변으로 2개 이상의 반대채권을 주장하였는데 법원이 그중 어느 하나의 반대채권의 존재를 인정하여 수동채권의 일부와 대등액에서 상계하는 판단을 하고, 나머지 반대채권들은 모두 부존재한다고 판단하여 그 부분 상계항변은 배척한 경우에, 수동채권 중 위와 같이 상계로 소멸하는 것으로 판단된 부분은 피고가 주장하는 반대채권들 중 그 존재가 인정되지 않은 채권들에 관한 분쟁이나 그에 관한 법원의 판단과는 관련이 없어 기판력의 관점에서 동일하게 취급할 수 없으므로, 그와 같이 반대채권들이 부존재한다는 판단에 대하여 기판력이 발생하는 전체 범위는 위와 같이 상계를 마친 후의 수동채권의 잔액을 초과할 수 없다고 보아야 한다. 그리고 이러한 법리는 피고가 주장하는 2개 이상의 반대채권의 원리금 액수의 합계가 법원이 인정하는 수동채권의 원리금 액수를 초과하는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 이때 `부존재한다고 판단된 반대채권`에 관하여 법원이 그 존재를 인정하여 수동채권 중 일부와 상계하는 것으로 판단하였을 경우를 가정하더라도, 그러한 상계에 의한 수동채권과 당해 반대채권의 차액 계산 또는 상계충당은 수동채권과 당해 반대채권의 상계적상의 시점을 기준으로 하였을 것이고, 그 이후에 발생하는 이자, 지연손해금 채권은 어차피 그 상계의 대상이 되지 않았을 것이므로, 위와 같은 가정적인 상계적상 시점이 `실제 법원이 상계항변을 받아들인 반대채권`에 관한 상계적상 시점보다 더 뒤라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 앞에서 본 기판력의 범위의 상한이 되는 `상계를 마친 후의 수동채권의 잔액`은 수동채권의 `원금`의 잔액만을 의미한다고 보아야 한다(대판 2018.8.30. 2016다46338).

ⓓ 상계항변의 철회

- 최근 판례는 상계판단에 기판력을 인정한 취지는, 기판력을 인정하지 않는다면 상계주장의 상대방은 상계를 주장한 자가 그 자동채권을 이중으로 행사하는 것에 의하여 불이익을 입을 수 있게 될 뿐만 아니라, 상계 주장에 대한 판단을 전제로 이루어진 원고의 청구권의 존부에 대한 전소의 판결이 결과적으로 무의미하게 될 우려가 있게 되므로, 이를 막기 위함인데 선행소송에서 상계항변을 철회한 경우 이는 자동채권을 이중으로 행사하는 것이 아니며, 원고의 청구권의 존부에 대한 전소의 판결이 결과적으로 무의미하게 될 우려가 없으므로 상계항변에 관하여 기판력이 발생하지 않는다(대판 2022.2.17. 2021다275741)고 판시하고 있다. 선행소송에서 상계항변의 철회로 인하여 상계항변에 관하여 판단하지 않아 자동채권의 존부에 대해 실질적으로 본안판단을 하지 않았으므로 기판력이 발생하지 않는다는 것이다.

ⓔ 기판력 범위의 기재

- 상계를 주장하면 그것이 받아들여지든 아니든 상계하자고 대항한 액수에 대하여 기판력이 생긴다(민사소송법 제216조 제2항). 따라서 여러 개의 자동채권이 있는 경우에 법원으로서는 그중 어느 자동채권에 대하여 어느 범위에서 상계의 기판력이 미치는지 판결이유 자체로 당사자가 분명하게 알 수 있을 정도까지는 밝혀 주어야 한다. 그러므로 상계항변이 이유 있는 경우에는, 상계에 의하여 소멸되는 채권의 금액을 일일이 계산할 것까지는 없다고 하더라도, 최소한 상계충당이 지정충당에 의하게 되는지 법정충당에 의하게 되는지 여부를 밝히고, 지정충당이 되는 경우라면 어느 자동채권이 우선 충당되는지를 특정하여야 할 것이며, 자동채권으로 이자나 지연손해금채권이 함께 주장되는 경우에는 그 기산일이나 이율 등도 구체적으로 특정해 주어야 할 것이다(대판 2011.8.25. 2011다24814).

ⓔ 기판력의 작용국면

ⓐ 기판력이 발생하여 소의 이익이 부정되는 경우

- 기판력은 후소의 소송물이 전소의 소송물과 동일・선결・모순관계에 있을 경우 작용하게 되는데 기판력이 발생한 자동채권과 동일한 채권을 후소의 소송물로 하는 경우 기판력이 후소에 작용한다. 따라서 판례는 예비적 반소의 원인채권인 계약금반환채권에 기한 상계항변이 다른 사건에서 인용되어 이미 확정된 이상, 이 사건 예비적 반소는 소의 이익이 없게 되어 부적법하게 되었으므로, 원심판결 중 이 사건 예비적 반소에 관한 부분은 상고이유에 대하여 살펴볼 필요 없이 그대로 유지할 수 없다(대판 2010.8.26. 2010다30966)고 판시하고 있다.

ⓑ 기판력이 발생하지 않아 소의 이익이 인정되는 경우

- 판례는 소송상 방어방법으로서의 상계항변은 통상 수동채권의 존재가 확정되는 것을 전제로 하여 행하여지는 일종의 예비적 항변으로서, 소송상 상계의 의사표시에 의해 확정적으로 그 효과가 발생하는 것이 아니라 당해 소송에서 수동채권의 존재 등 상계에 관한 법원의 실질적 판단이 이루어지는 경우에 비로소 실체법상 상계의 효과가 발생한다. 따라서 원고의 소구채권 자체가 인정되지 않는 경우 더 나아가 피고의 상계항변의 당부를 따져볼 필요도 없이 원고 청구가 배척될 것이므로, `원고의 소구채권 그 자체를 부정하여 원고의 청구를 기각한 판결`과 `소구채권의 존재를 인정하면서도 상계항변을 받아들인 결과 원고의 청구를 기각한 판결`은 민사소송법 제216조에 따라 기판력의 범위를 서로 달리하고, 후자의 판결에 대하여 피고는 상소의 이익이 있다(대판 2018.8.30. 2016다46338)고 한다.

④ 법률판단

- 판결이유 중에서 한 법률판단에도 기판력이 발생하지 아니한다. 여기의 법률판단에는 추상적 법규의 해석적용은 물론 구체적인 사건에 대한 법률해석 판단도 포함된다.

2. 기판력의 시적 범위

(1) 기판력의 표준시

- 기판력의 시적 범위는 전소확정판결의 기판력이 어느 시점의 권리관계의 존부에 발생하는지 확정하는 것을 말한다. 민사소송에 있어서 당사자는 사실심의 변론종결 시까지 소송자료를 제출할 수 있고, 법원은 그때까지 제출된 소송자료를 기초로 하여 종국판결을 하기 때문에 기판력의 표준시는 사실심의 변론종결 시가 된다(민소법 제218조). 물론 무변론판결의 기판력의 표준시는 판결선고 시이다. 따라서 표준시 전의 과거의 법률관계에 관하여는 기판력이 발생하지 아니한다. 즉 표준시에 권리가 존재한다는 판결이 확정된 후 표준시 전에는 권리가 부존재한다는 주장을 할 수 있고, 표준시에 권리가 부존재한다는 판결이 확정된 후 표준시 전에는 존재한다는 주장을 할 수 있다. 물론 표준시 후의 장래의 법률관계에도 기판력이 발생하지 아니한다. 판례는 확정판결의 기판력은 사실심의 최종변론종결 당시의 권리관계를 확정하는 것이므로, 원고의 청구 중 확정판결의 사실심 변론종결 시 후의 이행지연으로 인한 손해배상(이자) 청구 부분은 그 선결문제로서 확정판결에 저촉되는 금원에 대한 피고의 지급의무의 존재를 주장하게 되어 논리상 확정판결의 기판력의 효과를 받게 되는 것이라고 할 것이나 그 외의 부분(변론종결 당시까지의 부분)의 청구는 확정판결의 기판력의 효과를 받지 않는다(대판 1976.12.14. 76다1488)고 하여 같은 취지로 판시하고 있다.

(2) 변론종결 전에 존재한 사유

① 실권의 범위

- 표준시 전에 당사자가 제출할 수 있었던 공격방어방법은 기판력의 실권효에 의하여 차단되어 후소에서 이를 주장할 수 없다. 소송자료를 제출하지 못한 데 과실유무는 불문한다(대판 1980.5.13. 80다473).

㉮ 원고가 패소한 경우

- 전소에서 원고가 패소한 경우, 즉 원고가 증여를 원인으로 한 소유권확인청구의 소에서 패소확정된 뒤 원고가 변론종결 전에 주장할 수 있었던 상속사실을 들어 소유권확인의 소를 제기한 경우 또는 원고가 소유권에 기한 토지인도청구소송에서 소유권이 없음을 이유로 패소확정된 뒤 원고가 변론종결 전에 주장할 수 있었던 원고에게로 소유권이 환원된 사실을 들어 동일한 소를 제기한 경우에는 후소는 전소의 기판력에 저촉된다.

㉯ 피고가 패소한 경우

- 예를 들면 원고가 청구권을 주장하면서 승소확정판결을 받았다면 패소확정된 피고가 청구이의의 소나 채무부존재확인의 소를 제기하면서 전소 변론종결 전에 발생한 변제・면제・소멸시효완성 등의 채무소멸사유를 주장할 수 없다. 또한 변론종결 전에 존재하였으나 제출하지 못했던 증거를 발견하여도 후

소에서 증거로 제출할 수 없다.

㈐ **실권되는 범위**

- 어음발행사실에 기해 어음금청구를 하였다가 패소판결을 받고 확정된 뒤 전소 변론종결 전에 주장할 수 있었던 대여사실을 주장하면서 대여금청구의 소를 제기하는 경우와 같이 전소의 사실관계와 무관하고 모순되지 아니한 사실관계가 실권되는지 여부가 문제된다. 구소송물이론과 이원설에서는 대여사실은 별개의 청구원인사실로 소송물이 달라서 기판력의 객관적 범위에서 작용하지 아니하므로 시적 범위에서 전소 변론종결 전에 발생한 것이라고 하더라도 차단되지 아니한다고 한다. 신소송물이론 중 일원설에 의하면서도 위의 경우처럼 전소의 사실관계와 무관하고 모순되지 아니한 사실관계의 경우에는 차단되지 아니한다고 주장하는 견해도 있다. 생각건대 신소송물이론 중 일원설은 일원설로 출발하여 이원설과 같은 결론에 이른다는 점에서 판례의 태도인 구소송물이론이 타당하다고 판단된다.

② **변론종결 전의 한정승인사실**

㉮ **한정승인의 의의**

- 한정승인이란 승인을 하지만 피상속인의 채무와 유증에 의한 채무는 상속재산의 한도에서 변제하고 상속인의 고유재산으로 책임을 지지 않는 것을 말한다. 상속인이 한정승인을 한 경우 특별한 사정이 없는 한 상속채무는 전부 승계되지만 책임은 상속채무의 범위 내에서만 부담한다.

㉯ **한정승인을 이유로 한 청구이의의 소의 적법 여부**

㉠ **문제점**

- 변론종결 전에 한정승인을 하였음에도 불구하고 이를 주장하지 않은 경우 후에 한정승인을 주장하면서 청구이의의 소를 제기할 수 있는지 문제된다.

㉡ **학설**

- 상속인이 전소에서 한정승인의 항변을 하지 아니하면 책임의 범위는 현실적인 심판대상으로 등장하지 않고 주문과 이유에서도 판단되지 않으므로 상속인의 고유재산에는 기판력이 미치지 않아 청구이의의 소를 제기할 수 있다는 긍정설과 한정승인을 주장하지 않아 주문에서 채무범위만 명시해 책임범위에 관한 유보가 없는 판결이 확정돼도 무한책임을 판시한 것이고 한정승인사실은 변론종결 전의 사유이므로 적법한 청구이의의 사유가 될 수 없다는 부정설이 대립하고 있다.

㉢ **판례**

- 판례는 채권자가 피상속인의 금전채무를 상속한 상속인을 상대로 그 상속채무의 이행을 구하여 제기한 소송에서 채무자가 한정승인 사실을 주장하지 않으면 책임의 범위는 현실적인 심판대상으로 등장하지 아니하여 주문에서는 물론 이유에서도 판단되지 않으므로 그에 관하여 기판력이 미치지 않는다. 그러므로 채무자가 한정승인을 하고도 채권자가 제기한 소송의 사실심 변론종결 시까지 그 사실을 주장하지 아니하여 책임의 범위에 관한 유보가 없는 판결이 선고되어 확정되었다고 하더라도, 채무자는 그 후 위 한정승인 사실을 내세워 청구에 관한 이의의 소를 제기할 수 있다(대판 2006.10.13. 2006다23138)고 한다.

㉣ **검토**

- 한정승인에 의한 책임제한은 집행단계에서 문제되는 것이므로 전소 확정판결의 기판력은 상속인의 고유재산에는 미치지 아니한다고 보는 것이 타당하다. 따라서 상속인은 강제집행단계에서 한정승인을 주장하여 청구이의의 소를 제기할 수 있다고 할 것이다.

③ **변론종결 전의 상속포기사실**

㉮ **상속포기의 의의**

- 상속포기란 상속으로 인하여 발생하는 모든 권리의무의 승계를 부인하고 처음부터 상속인이 아니었던 것으로 하려는 상속인의 단독의 의사표시를 말한다. 상속인이 상속포기를 한 경우 상속인은 처음부터 상속인이 아닌 것으로 본다(민법 제1042조).

㉯ **상속포기를 이유로 한 청구이의의 소의 적법 여부**

- 판례는 채무자가 한정승인을 하였으나 채권자가 제기한 소송의 사실심 변론종결 시까지 이를 주장하지 아니하는 바람에 책임의 범위에 관하여 아무런 유보 없는 판결이 선고·확정된 경우라 하더라도 채무자가 그 후 위 한정승인 사실을 내세워 청구에 관한 이의의 소를 제기하는 것이 허용되는 것은, 한정승인에 의한 책임의 제한은 상속채무의 존재 및 범위의 확정과는 관계없이 다만 판결의 집행 대상을 상속재산의 한도로 한정함으로써 판결의 집행력을 제한할 뿐으로, 채권자가 피상속인의 금전채무를 상속한 상속인을 상대로 그 상속채무의 이행을 구하여 제기한 소송에서 채무자가 한정승인 사실을 주장하지 않으면 책임의 범위는 현실적인 심판대상으로 등장하지 아니하여 주문에서는 물론 이유에서도 판단되지 않는 관계로 그에 관하여는 기판력이 미치지 않기 때문이다. 위와 같은 기판력에 의한 실권효 제한의 법리는 채무의 상속에 따른 책임의 제한 여부만이 문제되는 한정승인과 달리 상속에 의한 채무의 존재 자체가 문제되어 그에 관한 확정판결의 주문에 당연히 기판력이 미치게 되는 상속포기의 경우에는 적용될 수 없다(대판 2009.5.28. 2008다79876)고 판시하고 있다. 생각건대 상속채무를 인정하는 전소판결이 확정되었고 후소인 청구이의의 소에서의 상속포기 주장은 상속채무 자체를 부정하는 주장이므로 기판력의 객관적 범위에서 모순관계로 작용하고 시적 범위에서 전소 변론종결 전의 사유이므로 차단된다는 것으로 이해해야 한다. 다만, 판례는 예외적으로 확정판결의 변론종결 전에 가정법원에 상속포기 신고를 하였다고 하더라도 변론종결 후에 상속포기 심판을 송달받았다면 그 상속포기는 청구이의의 사유에 해당한다(대판 2004.6.25. 2004다20401)고 한다.

(3) **변론종결 뒤에 발생한 새로운 사유**

- 전소 변론종결 뒤에 발생한 사유는 실권되지 아니하므로 당사자는 후소에서 전소 변론종결 뒤의 사유를 가지고 전소 확정판결의 기판력을 다툴 수 있고 법원도 확정판결의 내용과 달리 판단할 수 있다.

① **기판력에 저촉되지 않는 사례**

㉮ **원고패소의 경우**

㉠ **변론종결 후의 변제**

- 전소에서 피담보채무의 변제로 양도담보권이 소멸하였음을 원인으로 한 소유권이전등기의 회복 청구가 기각되었다고 하더라도, 장래 잔존 피담보채무의 변제를 조건으로 소유권이전등기의 회복을 청구하는 것은 전소의 확정판결의 기판력에 저촉되지 아니한다(대판 2014.1.23. 2013다64793).

㉡ **변론종결 후의 기한도래 또는 조건성취**

- 판결이 확정되면 법원이나 당사자는 확정판결에 반하는 판단이나 주장을 할 수 없는 것이나, 이러한 확정판결의 효력은 그 표준시인 사실심 변론종결 시를 기준으로 하여 발생하는 것이므로, 그 이후에 새로운 사유가 발생한 경우까지 전소의 확정판결의 기판력이 미치는 것은 아니므로, 전소에서 정지조건 미성취를 이유로 청구가 기각되었다 하더라도 변론종결 후에 그 조건이 성취되었다면, 이는 변론종결 뒤의 취소권이나 해제권과 같은 형성권 행사의 경우와는 달리 동일한 청구에 대하여 다시 소를 제기할 수 있다(대판 2002.5.10. 2000다50909).

㉢ **변론종결 후의 재산분할협의**

- 소유권확인청구의 소송물은 소유권 자체의 존부이므로, 전소에서 원고가 소유권을 주장하였다가 패소 판결이 확정되었다고 하더라도, 전소 변론종결 후에 소유권을 새로이 취득하였다면 전소의 기판력이 소유권확인을 구하는 후소에 미칠 수 없는데, 상속재산분할협의가 전소 변론종결 후에 이루어졌다면 비록 상속재산분할의 효력이 상속이 개시된 때로 소급한다 하더라도, 상속재산분할협의에 의한 소유권 취득은 전소 변론종결 후에 발생한 사유에 해당한다.

따라서 전소에서 원고가 단독상속인이라고 주장하여 소유권확인을 구하였으나 공동상속인에 해당한다는 이유로 상속분에 해당하는 부분에 대해서만 원고의 청구를 인용하고 나머지 청구를 기각하는 판결이 선고되어 확정되었다면, 전소의 기판력은 전소 변론종결 후에 상속재산분할협의에 의해 원고가 소유권을 취득한 나머지 상속분에 관한 소유권확인을 구하는 후소에는 미치지 않는다 (대판 2011.6.30. 2011다24340).

㉣ 변론종결 후의 이행 가능

- 판례에 의하면 을로부터 병 앞으로 소유권이전등기가 경료되어 있기 때문에 을의 갑에 대한 소유권이전등기 의무가 이행불능이라는 이유로 갑이 을을 상대로 한 소유권이전등기청구소송에서 청구기각 판결이 확정된 후, 갑이 병을 상대로 소유권이전등기말소청구소송을 제기하여 승소판결을 받아 등기부상 소유권을 회복한 경우, 을은 갑에 대하여 소유권이전등기 의무를 부담한다고 봄이 신의성실의 원칙상 당연하므로, 종전의 갑 패소판결 확정 후 사정변경이 생긴 이상 을에 대하여 갑 앞으로 소유권이전등기 절차의 이행을 명한 원심판결이 종전의 갑 패소판결의 기판력에 저촉되지 않는다(대판 1995.9.29. 94다46817)고 한다.

㉤ 피고 패소의 경우

- 원고가 소비대차계약 사실을 주장하면서 대여금청구의 소를 제기하여 승소확정된 뒤 패소한 피고는 후소에서 변론종결 뒤에 발생한 사유인 변제・면제・소멸시효 등을 주장하면서 청구이의의 소(민사집행법 제44조)를 제기할 수 있다.

② 변론종결 뒤에 발생한 사유 여부

㉮ 사실자료에 한정

- 변론종결 후에 발생한 새로운 사유란 새로운 사실관계를 말하는 것일 뿐 기존의 사실관계에 대한 새로운 증거자료가 있다거나 새로운 법적 평가 또는 그와 같은 법적 평가가 담긴 다른 판결이 존재한다는 등의 사정은 포함되지 아니한다(대판 2016.8.30. 2016다222140). 따라서 법률・판례의 변경, 기초가 된 행정처분의 변경, 사실에 대한 법적 평가의 변경은 포함되지 아니한다. 최근 판례도 같은 취지에서 승소판결이 확정된 후 소송촉진 등에 관한 특례법의 변경으로 소송촉진법에서 정한 지연손해금 이율이 달라졌다고 하더라도 그로 인하여 선행 승소확정판결의 효력이 달라지는 것은 아니고, 확정된 선행판결과 달리 변경된 소송촉진법상의 이율을 적용하여 선행판결과 다른 금액을 원고의 채권액으로 인정할 수 있는 것도 아니다(대판 2019.8.29. 2018다215272)고 판시하고 있다.

㉯ 현저한 사정변경

㉠ 여명단축으로 인한 치료비반환청구

- 판례는 확정판결이 실체적 권리관계와 다르다 하더라도 그 판결이 재심의 소 등으로 취소되지 않는 한 그 판결의 기판력에 저촉되는 주장을 할 수 없어 그 판결의 집행으로 교부받은 금원을 법률상 원인 없는 이득이라 할 수 없는 것이므로, 불법행위로 인한 인신손해에 대한 손해배상청구소송에서 판결이 확정된 후 피해자가 그 판결에서 손해배상액 산정의 기초로 인정된 기대여명보다 일찍 사망한 경우라도 그 판결이 재심의 소 등으로 취소되지 않는 한 그 판결에 기하여 지급받은 손해배상금 중 일부를 법률상 원인 없는 이득이라 하여 반환을 구하는 것은 그 판결의 기판력에 저촉되어 허용될 수 없다(대판 2009.11.12. 2009다56665)고 판시하고 있다.

㉡ 임료상승으로 인한 차액청구

ⓐ 문제점

- 표준시의 임대료보다 임료가 현저하게 상승한 경우 차액청구를 위해 별소를 제기하는 것이 가능한지 문제된다.

ⓑ 학설

- 전소청구를 명시적 일부청구로 의제하여 별소로 차액청구가 가능하다고 하는 명시적 일부청구의제설, 경제사정의 변동 등 전소에서 제출할 수 없었던 사실관계는 변론종결 뒤의 사유에 해당하므로 후소에서 차단되지 않는다는 시적 한계설, 전소의 임료청구는 묵시적 일부청구이고, 임료 상승을 이유로 제기한 후소는 잔부청구로서 전소와 소송물이 동일하여, 전소 확정판결의 기판력에 저촉되어 부적법하므로 소각하해야 한다는 부정설이 대립하고 있다.

ⓒ 판례

- 판례는 토지의 소유자가 법률상 원인 없이 토지를 점유하고 있는 자를 상대로 장래의 이행을 청구하는 소로서, 그 점유자가 토지를 인도할 때까지 토지를 사용・수익함으로 인하여 얻을 토지의 임료에 상당하는 부당이득금의 반환을 청구하여, 그 청구의 전부나 일부를 인용하는 판결이 확정된 경우에, 그 소송의 사실심 변론종결 후에 토지의 가격이 현저하게 앙등하고 조세 등의 공적인 부담이 증대되었을 뿐더러 그 인근 토지의 임료와 비교하더라도 그 소송의 판결에서 인용된 임료액이 상당하지 아니하게 되는 등 경제적 사정의 변경으로 당사자 간의 형평을 심하게 해할 특별한 사정이 생긴 때에는, 일부청구임을 명시하지는 아니하였지만 명시한 경우와 마찬가지로 그 청구가 일부청구이었던 것으로 보아, 전소판결의 기판력이 그 일부청구에서 제외된 위 차액에 상당하는 부당이득금의 청구에는 미치지 않는 것이라고 해석하여 토지의 소유자는 점유자를 상대로 새로 소를 제기하여 전소판결에서 인용된 임료액과 적정한 임료액의 차액에 상당하는 부당이득금의 반환을 청구할 수 있다고 봄이 상당하다(대판 1993.12.21. 92다46226[전합])고 하여 명시적 일부청구의제설을 취하고 있다.

ⓓ 검토

- 생각건대 소유자의 권리보호의 필요성과 경제사정의 변동 등 액수산정의 기초가 되는 사실의 변경을 새로운 사실자료나 소송물로 볼 수 없다는 점에서 명시적 일부청구의제설이 타당하다고 판단된다.

㉢ 후유증에 의한 확대손해 청구

ⓐ 문제점

- 불법행위에 의한 신체의 침해를 이유로 하는 손해배상청구소송에서 판결이 확정된 후에 후유증에 의한 확대손해가 발생한 경우 다시 소를 제기하여 손해배상을 청구할 수 있는지 문제된다.

ⓑ 학설

- 치료비의 추가청구를 명시적 일부청구 후의 잔부청구로 의제하여 전소판결의 기판력이 미치지 아니한다는 명시적 일부청구의제설, 후유증에 의한 확대손해의 발생은 기판력의 시적 한계를 벗어난 사실이므로 전소의 기판력에 의하여 차단되지 아니한다는 시적 한계설, 전소 변론종결 시까지 제출을 기대할 수 없었던 손해는 전소 청구와는 별개의 소송물이라는 별개소송물설이 대립하고 있다.

ⓒ 판례

- 판례는 불법행위로 인한 적극적 손해의 배상을 명한 전소송의 변론종결 후에 새로운 적극적 손해가 발생한 경우에 그 소송의 변론종결 당시 그 손해의 발생을 예견할 수 없었고 또 그 부분 청구를 포기하였다고 볼 수 없는 등 특별한 사정이 있다면 전소송에서 그 부분에 관한 청구가 유보되어 있지 않다고 하더라도 이는 전소송의 소송물과는 별개의 소송물이므로 전소송의 기판력에 저촉되는 것이 아니라고 하여 식물인간 피해자의 여명이 종전의 예측에 비하여 수년 연장되어 그에 상응한 향후치료, 보조구 및 개호 등이 추가적으로 필요하게 된 경우, 전소의 변론종결 당시에는 예견할 수 없었던 새로운 중한 손해로서 전소의 기판력에 저촉되지 않는다(대판 2007.4.13. 2006다78640)고 판시하고 있다.

ⓓ 검토

- 생각건대 전소의 변론종결 당시 그 손해의 발생을 예견할 수 없었고 함께 청구하는 것을 기대할 수 없었던 경우에는 전소의 소송물과는 별개의 소송물로 보아 기판력이 미치지 아니한다고 하는 것도 피해자를 보호하기 위해 가능한 법리라고 판단된다.

(4) 변론종결 뒤의 형성권 행사

① 문제점

- 전소 변론종결 전에 발생한 형성권을 변론종결 이후에 행사하여 청구이의의 소나 채무부존재확인의 소로써 다툴 수 있는지 문제된다.

② 형성권 행사

㉮ 취소권 등 형성권 일반

- 판례는 변론종결 시 전에 행사할 수 있었던 취소권(대판 1959.9.24. 4291민상830), 해제권(대판 1979.8.14. 79다1105)에 대하여는 변론종결 시 후에 이를 행사하면 차단된다고 한다. 즉 확정된 법률관계에 있어 동 확정판결의 변론종결 전에 이미 발생하였던 취소권을 그 당시에 행사하지 않음으로 인하여 취소권자에게 불리하게 확정된 경우 그 확정 후 취소권을 뒤늦게 행사함으로써 동 확정의 효력을 부인할 수 없다(대판 1979.8.14. 79다1105). 백지보충권에 대하여도 약속어음의 소지인이 어음요건의 일부를 흠결한 이른바 백지어음에 기하여 어음금 청구소송(이하 `전소`)을 제기하였다가 위 어음요건의 흠결을 이유로 청구기각의 판결을 받고 위 판결이 확정된 후 위 백지 부분을 보충하여 완성한 어음에 기하여 다시 전소의 피고에 대하여 어음금 청구소송(이하 `후소`)을 제기한 경우에는, 원고가 전소에서 어음요건의 일부를 오해하거나 그 흠결을 알지 못했다고 하더라도, 전소와 후소는 동일한 권리 또는 법률관계의 존부를 목적으로 하는 것이어서 그 소송물은 동일한 것이라고 보아야 한다. 그리고 확정판결의 기판력은 동일한 당사자 사이의 소송에 있어서 변론종결 전에 당사자가 주장하였거나 주장할 수 있었던 모든 공격 및 방어방법에 미치는 것이므로, 약속어음의 소지인이 전소의 사실심 변론종결일까지 백지보충권을 행사하여 어음금의 지급을 청구할 수 있었음에도 위 변론종결일까지 백지 부분을 보충하지 않아 이를 이유로 패소판결을 받고 그 판결이 확정된 후에 백지보충권을 행사하여 어음이 완성된 것을 이유로 전소 피고를 상대로 다시 동일한 어음금을 청구하는 경우에는, 위 백지보충권 행사의 주장은 특별한 사정이 없는 한 전소판결의 기판력에 의하여 차단되어 허용되지 않는다(대판 2008.11.27. 2008다59230) 같은 취지로 판시하고 있다.

㉯ 상계권

㉠ 학설

- 법적 안정성을 이유로 변론종결한 뒤에는 상계권을 행사할 수 없다는 실권설, 실권 여부는 형성권을 실제로 행사한 시점을 기준으로 하여 판단해야 하므로 상계권은 실권되지 아니한다는 비실권설, 다른 형성권은 실권되지만 상계권은 소구채권의 하자의 문제가 아니고 출혈적 방어방법인 점으로 고려할 때 상계권은 실권되지 않는다는 상계권비실권설, 다른 형성권은 실권되지만 상계권의 경우에는 다른 형성권과는 달리 전소에서 행사할 수 있음을 알고 불행사한 경우에 실권된다는 제한적 상계권실권설이 대립하고 있다.

㉡ 판례

- 판례는 당사자 쌍방의 채무가 서로 상계적상에 있다 하더라도 그 자체만으로 상계로 인한 채무소멸의 효력이 생기는 것은 아니고, 상계의 의사표시를 기다려 비로소 상계로 인한 채무소멸의 효력이 생기는 것이므로, 채무자가 채무명의인 확정판결의 변론종결 전에 상대방에 대하여 상계적상에 있는 채권을 가지고 있었다 하더라도 채무명의인 확정판결의 변론종결 뒤에 이르러 비로소 상계의 의사표시를 한 때에는 민사집행법 제44조 제2항이 규정하는 `이의원인이 변론종결 뒤에 생긴 때`에 해당하는 것으로서, 당사자가 채무명의인 확정판결의 변론종결 전에 자동채권의 존재를 알았는가 몰랐는가에 관계없이 적법한 청구이의 사유로 된다(대판 1998.11.24. 98다25344)고 하여 상계권비실권설의 태도를 취하고 있다.

㉢ 검토

- 상계권은 소구채권의 하자의 문제가 아니고 출혈적 방어방법이고 이를 허용하지 아니하는 경우에는 피고에게 너무 가혹하다는 점을 고려하면 상계권비실권설이 타당하다고 판단된다.

㉰ 건물매수청구권

㉠ 학설

- 법적 안정성을 이유로 변론종결한 뒤에는 건물매수청구권을 행사할 수 없다는 실권설, 실권 여부는 형성권을 실제로 행사한 시점을 기준으로 하여 판단해야 하므로 건물매수청구권은 실권되지 아니한다는 비실권설, 다른 형성권은 실권되지만 건물매수청구권은 실권되지 않는다는 건물매수청구권비실권설, 다른 형성권은 실권되지만 건물매수청구권의 경우에는 다른 형성권과는 달리 전소에서 행사할 수 있음을 알고 불행사한 경우에 실권된다는 제한적 건물매수청구권실권설이 대립하고 있다.

㉡ 판례

- 판례는 건물의 소유를 목적으로 하는 토지 임대차에 있어서, 임대차가 종료함에 따라 토지의 임차인이 임대인에 대하여 건물매수청구권을 행사할 수 있음에도 불구하고 이를 행사하지 아니한 채, 토지의 임대인이 임차인에 대하여 제기한 토지인도 및 건물철거청구소송에서 패소하여 그 패소판결이 확정되었다고 하더라도, 그 확정판결에 의하여 건물철거가 집행되지 아니한 이상 토지의 임차인으로서는 건물매수청구권을 행사하여 별소로써 임대인에 대하여 건물매매대금의 지급을 구할 수 있다(대판 1995.12.26. 95다42195)고 하여 건물매수청구권비실권설의 태도를 취하고 있다.

㉢ 검토

- 건물매수청구권은 원고의 청구 자체의 하자가 있다는 주장을 하는 것이 아니라 별개의 독립된 매매대금채권을 행사하는 것이고, 법률적 지식이 부족한 임차인을 보호할 필요가 있다는 점을 고려할 때 건물매수청구권비실권설이 타당하다고 판단된다.

(5) 정기금판결에 대한 변경의 소

① 의의

㉮ 개념

- 정기금판결에 대한 변경의 소란 정기금의 지급을 명한 판결이 확정된 뒤에 그 액수산정의 기초가 된 사정이 현저하게 바뀐 경우에 장차 지급할 정기금 액수를 바꾸어 달라는 소를 말한다(민소법 제252조 제1항).

㉯ 취지

- 변경의 소는 사정변경의 원칙이 소송법에 반영된 것으로 현실로 발생한 사실이 예측과 다른 경우 판결을 변경하여 주는 것이 당사자 사이의 형평에 부합하다고 본 것이다.

② 변경의 소의 요건

㉮ 소송요건

㉠ 정기금의 지급을 명하는 판결

- 정기금으로 급부를 명한 판결만 대상이다. 중간이자를 공제하고 일시금 배상판결을 한 경우에도 변경의 소를 허용하자는 견해도 있으나 정기금이라고 규정한 현행법의 해석상 어려울 것이다.

㉡ 집행 전 현저한 사정변경의 주장

- 변경의 소는 정기금판결의 집행이 종료하면 권리보호이익이 없기 때문에 집행이 종료하기 전에 전소 변론종결 이후에 현저한 사정변경이 있음을 주장하며 제기하여야 한다.

㉢ 기타 소송요건의 구비

- 원칙적으로 전소의 판결의 당사자가 변경의 소의 당사자가 되겠지만 승계로 제3자에게 기판력이 미치는 경우에는 그 제3자도 당사자가 될 수 있다. 변경의 소는 제1심법원의 전속관할이다(민소법 제252조 제2항).

㉣ **본안요건**

㉠ **현저한 사정변경**

- 전소판결의 액수산정의 기초가 되었던 객관적 상황이 현저하게 변경되어야 한다. 사정변경에는 지가의 상승, 후유장애의 호전, 임금의 증가 등이 포함되나 판례의 변경 등 법률적 변경이 포함되지 않는다. 사정변경은 현저해야 하므로 당사자 사이의 형평을 크게 침해할 특별한 사정을 말한다고 해야 한다. 판례도 같은 취지에서 점유 토지의 인도 시까지 정기금의 지급을 명하는 판결이 확정된 뒤에 그 판결의 변경을 구하는 취지의 소가 제기된 사안에서, 전소의 변론종결일 후 후소의 원심변론종결 당시까지 점유토지의 공시지가가 2.2배 상승하고 ㎡당 연임료가 약 2.9배 상승한 것만으로는, 전소의 확정판결 후에 그 액수 산정의 기초가 된 사정이 현저하게 바뀜으로써 당사자 사이의 형평을 크게 침해할 특별한 사정이 생겼다고 할 수 없다(대판 2009.12.24. 2009다64215)고 판시하고 있다.

㉡ **확정판결**

- 변경의 대상이 되는 판결은 확정되어야 한다. 확정 전에는 상소로 판결변경을 요구하면 된다. 변경의 소는 확정판결과 같은 효력을 가지는 인낙・화해・조정조서에 대하여도 인정됨을 유의하여야 한다.

㉢ **판결확정 후**

- 조문에는 `판결이 확정된 뒤`라고 규정되어 있지만 사실심 변론종결 뒤의 사정은 법원이 고려할 수 없으므로 `변론종결 뒤`라고 해석할 것이다. 판례에 의하면 판결 확정 뒤에 발생한 사정변경을 요건으로 하므로, 단순히 종전 확정판결의 결론이 위법・부당하다는 등의 사정을 이유로 본조에 따라 정기금의 액수를 바꾸어 달라고 하는 것은 허용될 수 없다(대판 2016.3.10. 2015다243996).

㉤ **관련 판례 (토지의 전 소유자가 무단 점유자를 상대로 제기한 부당이득반환청구소송의 변론종결 후에 토지의 소유권을 취득한 사람이 위 소송에서 확정된 정기금판결에 대하여 변경의 소를 제기하는 것이 적법한지 여부)**

- 민사소송법 제252조 제1항은 `정기금의 지급을 명한 판결이 확정된 뒤에 그 액수 산정의 기초가 된 사정이 현저하게 바뀜으로써 당사자 사이의 형평을 크게 침해할 특별한 사정이 생긴 때에는 그 판결의 당사자는 장차 지급할 정기금 액수를 바꾸어 달라는 소를 제기할 수 있다`라고 규정하고 있다. 이러한 정기금판결에 대한 변경의 소는 정기금판결의 확정 뒤에 발생한 현저한 사정변경을 이유로 확정된 정기금판결의 기판력을 예외적으로 배제하는 것을 목적으로 하므로, 확정된 정기금판결의 당사자 또는 민사소송법 제218조 제1항에 의하여 확정판결의 기판력이 미치는 제3자만 정기금판결에 대한 변경의 소를 제기할 수 있다. 한편 토지의 소유자가 소유권에 기하여 토지의 무단 점유자를 상대로 차임 상당의 부당이득반환을 구하는 소송을 제기하여 무단 점유자가 점유 토지의 인도 시까지 매월 일정 금액의 차임 상당 부당이득을 반환하라는 판결이 확정된 경우, 이러한 소송의 소송물은 채권적 청구권인 부당이득반환청구권이므로, 소송의 변론종결 후에 토지의 소유권을 취득한 사람은 민사소송법 제218조 제1항에 의하여 확정판결의 기판력이 미치는 변론을 종결한 뒤의 승계인에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 토지의 전 소유자가 제기한 부당이득반환청구소송의 변론종결 후에 토지의 소유권을 취득한 사람에 대해서는 소송에서 내려진 정기금 지급을 명하는 확정판결의 기판력이 미치지 아니하므로, 토지의 새로운 소유자가 토지의 무단 점유자를 상대로 다시 부당이득반환청구의 소를 제기하지 아니하고, 토지의 전 소유자가 앞서 제기한 부당이득반환청구소송에서 내려진 정기금판결에 대하여 변경의 소를 제기하는 것은 부적법하다(대판 2016.6.28. 2014다31721).

③ **심판절차**

㉮ **절차**

- 변경의 소의 당사자는 정기금지급판결을 받은 당사자와 그 승계인이다. 변경의 소에서는 변경된 사항에 대한 심리가 이루어져야 하므로 편의상 제1심 판결법원의 전속관할로 한다(민소법 제252조 제2항). 즉, 확정판결이 항소심법원 또는 상고심법원 판결이라도 제1심 수소법원의 전속관할이다.

㉯ **종국판결**

- 종전 정기금판결의 기판력이 배제되고 새로운 사정을 기초로 다시 법률관계를 확정하게 된다. 인용판결을 하는 경우 원판결을 감액 또는 증액하는 판결주문을 선고한다. 변경의 소제기를 기점으로 하여 장차 지급할 정기금액수만이 변경판결의 대상이다(대판 2009.12.24. 2009다64215). 변경의 소의 요건이 부존재하면 청구기각판결을 한다.

㉰ **집행정지**

- 변경의 소가 제기되었다고 하더라도 정기금판결의 집행력에 기한 강제집행이 정지되는 것은 아니므로 별도의 집행정지신청을 하여 정지결정을 받아야 한다.

④ **적용범위**

㉮ **추가청구 또는 청구이의의 소와의 관계**

- 변경의 소로는 변경의 소제기일 이후의 증감액만 구제되기 때문에 전소 변론종결 후부터 변경의 소제기 전까지의 부분에 대해 현저한 사정변경이 있는 경우에는 추가청구 또는 청구이의의 소를 제기해야 한다.

㉠ **변경의 소제기일 전 부분에 대해 현저한 사정변경이 없는 경우**

- 판례는 점유 토지의 인도 시까지 정기금의 지급을 명하는 판결이 확정된 뒤에 그 판결의 변경을 구하는 취지의 소가 제기된 사안에서, 피고들의 점유 부분이 전소의 변론종결 당시와 동일하다면, 원고의 이 사건 청구 중 이 사건 소제기일 전까지의 기간에 해당하는 부분은 확정판결이 있었던 전소와 소송물이 동일하여 그 확정판결의 기판력이 미친다고 할 것이어서, 그중 전소의 확정판결에서 원고가 승소한 부분(전소에서 원고의 청구가 인용된 금액에 해당하는 부분)에 해당하는 부분은 권리보호의 이익이 없고, 이를 초과하는 부분은 전소의 확정판결의 기판력에 저촉되는 것이어서 받아들일 수 없다(대판 2009.12.24. 2009다64215)고 한다.

㉡ **변경의 소제기일 전 부분에 대해 현저한 사정변경이 있는 경우**

- 판례는 확정판결은 주문에 포함한 것에 대하여 기판력이 있고, 변론종결 시를 기준으로 하여 이행기가 장래에 도래하는 청구권이더라도 미리 청구할 필요가 있는 경우에는 장래이행의 소를 제기할 수 있으므로, 이행판결의 주문에서 변론종결 이후 기간까지 급부의무의 이행을 명한 이상 확정판결의 기판력은 주문에 포함된 기간까지의 청구권의 존부에 대하여 미치는 것이 원칙이고, 다만 장래 이행기 도래분까지의 정기금의 지급을 명하는 판결이 확정된 경우 그 소송의 사실심 변론종결 후에 액수 산정의 기초가 된 사정이 뚜렷하게 바뀜으로써 당사자 사이의 형평을 크게 해할 특별한 사정이 생긴 때에는 전소에서 명시적인 일부청구가 있었던 것과 동일하게 평가하여 전소판결의 기판력이 차액 부분에는 미치지 않는다(대판 2011.10.13. 2009다102452)고 하여 명시적 일부청구 의제설의 태도를 취하고 있다.

㉯ **후유증에 의한 확대손해청구 가부**

㉠ **문제점**

- 후유증에 의한 확대손해가 발생한 경우 변경의 소를 제기하여 손해배상을 청구할 수 있는지 여부가 변경의 소의 소송물과 관련하여 문제된다.

㉡ **학설**

- 변경의 소는 재심의 소처럼 소송물이 전소 소송물과 동일하므로 전소 변론종결 시 예상하지 못한 후유증에 의한 확대손해는 전소 소송물과 별개의 소송물이어서 추가청구하면 되고 변경의 소의 대상은 아니라는 소송물동일설과 변경의 소는 재심의 소와는 달리 그 소송물은 전소판결 내용을 변경하여 달라는 변경청구권으로 전소 소송물과 다르고 예상하지 못한 확대손해의 경우에도 변경청구권만 발생하면 변경의 소가 허용된다는 소송물별개설이 대립하고 있다.

㉢ 판례

- 판례는 불법행위로 인한 적극적 손해의 배상을 명한 전소송의 변론종결 후에 새로운 적극적 손해가 발생한 경우에 그 소송의 변론종결 당시 그 손해의 발생을 예견할 수 없었고 또 그 부분 청구를 포기하였다고 볼 수 없는 등 특별한 사정이 있다면 전 소송에서 그 부분에 관한 청구가 유보되어 있지 않다고 하더라도 이는 전소송의 소송물과는 별개의 소송물이므로 전소송의 기판력에 저촉되는 것이 아니라고 하여 식물인간 피해자의 여명이 종전의 예측에 비하여 수년 연장되어 그에 상응한 향후치료, 보조구 및 개호 등이 추가적으로 필요하게 된 경우, 전소의 변론종결 당시에는 예견할 수 없었던 새로운 중한 손해로서 전소의 기판력에 저촉되지 않는다(대판 2007.4.13. 2006다78640)고 판시하고 있다.

㉣ 검토

- 전소와 후소의 소송물이 동일한 경우 기판력의 저촉의 문제를 해결하려는 변경의 소의 입법취지를 고려할 때 변경의 소는 소송물이 동일하다고 보아야 하므로 후유증에 의한 확대손해가 발생한 경우에는 변경의 소가 아니라 별소를 제기하여 손해배상을 청구할 수 있다고 할 것이다.

Ⅳ. 채권자취소소송의 주요논점

1. 채권자취소권의 요건사실

- 채무자가 채권자를 해함을 알고(사해의사) 재산권을 목적으로 한 법률행위(사해행위)를 한 때에는 채권자(피보전채권의 존재)는 그 취소 및 원상회복을 법원에 청구할 수 있다. 이에 대해 이익을 받은 자나 전득한 자가 그 행위 또는 전득 당시에 채권자를 해함을 알지 못했음을 항변할 수 있다(민법 제406조).

2. 채권자취소소송의 법적 성질

- 학설로는 채권자취소소송은 사해행위의 절대적 취소를 목적으로 하므로 채무자와 수익자를 공동피고로 해야 한다고 하는 형성소송설, 원상회복을 목적으로 하므로 수익자를 피고로 해야 한다는 이행소송설, 사해행위 취소를 구하는 형성소송과 넘어간 재산의 원상회복을 구하는 이행소송의 병합이라는 병합설이 대립하고 있으나 판례는 채권자취소권은 채무자의 사해행위를 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에서 상대적으로 취소하고 채무자의 책임재산에서 일탈한 재산을 회복하여 채권자의 강제집행이 가능하도록 하는 것을 본질로 하는 권리(대판 2008.4.24. 2007다84352)라고 하여 병합설의 태도를 취하고 있다.

3. 채권자취소소송의 피고적격

- 판례는 채권자가 채권자취소권을 행사하려면 사해행위로 인하여 이익을 받은 자나 전득한 자를 상대로 그 법률행위의 취소를 청구하는 소송을 제기하여야 되는 것으로서 채무자를 상대로 그 소송을 제기할 수는 없다(대판 2004.8.30. 2004다21923)고 한다.

4. 채권자취소소송 중 채권자취소소송의 제기의 중복소제기 여부

(1) 수인의 채권자가 채권자취소소송을 행사하는 경우

① 판례

- 채권자취소권의 요건을 갖춘 각 채권자는 고유의 권리로서 채무자의 재산처분 행위를 취소하고 그 원상회복을 구할 수 있는 것이므로 여러 명의 채권자가 동시에 또는 시기를 달리하여 사해행위취소 및 원상회복청구의 소를 제기한 경우 이들 소가 중복제소에 해당하지 아니할 뿐만 아니라, 어느 한 채권자가 동일한 사해행위에 관하여 사해행위취소 및 원상회복청구를 하여 승소판결을 받아 그 판결이 확정되었다는 것만으로는 그 후에 제기된 다른 채권자의 동일한 청구가 권리보호의 이익이 없게 되는 것은 아니고, 그에 기하여 재산이나 가액의 회복을 마친 경우에 비로소 다른 채권자의 사해행위취소 및 원상회복청구는 그와 중첩되는 범위 내에서 권리보호의 이익이 없게 된다(대판 2008.4.24. 2007다84352).

② 검토

- 채권자취소소송의 경우에는 채권자가 자신의 권리로서 채권자취소권을 행사하는 것이어서, 소송물은 각 채권자의 채권자취소권이 되므로 채권자들의 각 채권자취소소송은 서로 별개의 권리를 행사하는 것으로 볼 수 있어 중복소제기에 해당하지 아니한다.

(2) 채권자가 수익자를 피고로 채권자취소의 소를 이중으로 행사하는 경우

① 판례

- 채권자가 사해행위취소 및 원상회복청구를 하면서 보전하고자 하는 채권을 추가하거나 교환하는 것은 사해행위취소권과 원상회복청구권을 이유 있게 하는 공격방법에 관한 주장을 변경하는 것일 뿐이지 소송물 또는 청구 자체를 변경하는 것이 아니므로, 채권자가 보전하고자 하는 채권을 달리하여 동일한 법률행위의 취소 및 원상회복을 구하는 채권자취소의 소를 이중으로 제기하는 경우 전소와 후소는 소송물이 동일하다고 보아야 하고, 이는 전소나 후소 중 어느 하나가 승계참가신청에 의하여 이루어진 경우에도 마찬가지이다(대판 2012.7.5. 2010다80503).

② 검토

- 채권자취소소송에서 피보전채권은 공격방어방법에 불과하므로 피보전채권을 대여금채권에서 손해배상채권으로 변경하여도 전후 소송물은 동일하므로 후소는 중복소제기에 해당한다.

5. 채권자취소소송에서의 기판력의 범위

(1) 채무자 또는 채무자와 수익자와의 관계에서 기판력의 저촉 여부

① 채권자취소소송확정판결의 효력이 채무자 또는 채무자와 수익자 사이의 소송에 미치는지 여부

- 사해행위취소판결의 기판력은 그 취소권을 행사한 채권자와 그 상대방인 수익자 또는 전득자와의 상대적인 관계에서만 미칠 뿐 그 소송에 참가하지 아니한 채무자 또는 채무자와 수익자 사이의 법률관계에는 미치지 아니한다(대판 1988.2.23. 87다카1989).

② 채무자와 수익자 사이의 소송의 확정판결의 효력이 채권자취소소송에 미치는지 여부

- 채권자가 사해행위의 취소와 함께 수익자 또는 전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 사해행위취소의 판결을 받은 경우 수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한 원상회복 의무를 부담하게 될 뿐, 채권자와 채무자 사이에서 취소로 인한 법률관계가 형성되는 것은 아니다. 따라서 위와 같이 채무자와 수익자 사이의 소송절차에서 확정판결 등을 통해 마쳐진 소유권이전등기가 사해행위취소로 인한 원상회복으로써 말소된다고 하더라도, 그것이 확정판결 등의 효력에 반하거나 모순되는 것이라고는 할 수 없다(대판 2017.4.7. 2016다204783). 즉, 채무자와 수익자 사이의 소송의 확정판결의 효력이 채권자취소소송에 미치지 않는다는 취지이다.

(2) 각 채권자가 채권자취소 및 원상회복소송을 제기한 경우

① 기판력의 저촉 여부

- 채권자취소권의 요건을 갖춘 각 채권자는 고유의 권리로서 채무자의 재산처분 행위를 취소하고 그 원상회복을 구할 수 있는 것이므로(대판 2003.7.11. 2003다19558), 소송물이 달라서 기판력이 확장될 여지가 없다.

② 권리보호이익의 유무

- 어느 한 채권자가 동일한 사해행위에 관하여 채권자취소 및 원상회복청구를 하여 승소판결을 받아 그 판결이 확정되었다는 것만으로 그 후에 제기된 다른 채권자의 동일한 청구가 권리보호의 이익이 없어지게 되는 것은 아니고, 그에 기하여 재산이나 가액의 회복을 마친 경우에 비로소 다른 채권자의 채권자

취소 및 원상회복청구는 그와 중첩되는 범위 내에서 권리보호의 이익이 없게 된다(대판 2003.7.11. 2003다19558).

(3) 한 명의 취소채권자가 피보전권리를 달리하여 채권자취소권을 이중으로 행사하는 경우

- 이 경우는 피보전채권만 달리할 뿐 당사자와 소송물이 동일하므로 기판력에 저촉된다(대판 2012.7.5. 2010다80503).

(4) 채권자가 사해행위의 취소 및 원상회복으로 원물반환 청구를 하여 승소판결이 확정된 후에 다시 가액배상을 청구하는 것이 가능한지 여부

- 사해행위 후 목적물에 관하여 제3자가 저당권이나 지상권 등의 권리를 취득한 경우에는 수익자가 목적물을 저당권 등의 제한이 없는 상태로 회복하여 이전하여 줄 수 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 채권자는 원상회복 방법으로 수익자를 상대로 가액 상당의 배상을 구할 수도 있고, 채무자 앞으로 직접 소유권이전등기절차를 이행할 것을 구할 수도 있다. 이 경우 원상회복청구권은 사실심 변론종결 당시의 채권자의 선택에 따라 원물반환과 가액배상 중 어느 하나로 확정되며, 채권자가 일단 사해행위 취소 및 원상회복으로서 원물반환 청구를 하여 승소 판결이 확정되었다면, 그 후 어떠한 사유로 원물반환의 목적을 달성할 수 없게 되었다고 하더라도 다시 원상회복청구권을 행사하여 가액배상을 청구할 수는 없으므로 그 청구는 권리보호의 이익이 없어 허용되지 않는다(대판 2006.12.7. 2004다54978).

(5) 선행소송에 따른 가액반환 종료 후 동일 부동산에 대한 증가된 시가상당의 가액반환을 구하는 후행소송의 경우

- 동일한 사해행위에 관한 취소소송이 중첩된 경우, 선행소송에서 확정판결로 처분부동산의 감정 평가에 따른 가액반환이 이루어진 이상 후행소송에서 부동산의 시가를 다시 감정한 결과 위 확정판결에서 인정한 시가보다 평가액이 증가되었다 하더라도, 그 증가된 부분을 위 확정판결에서 인정한 부분과 중첩되지 않는 부분으로 보아 이에 대하여 다시 가액배상을 명할 수는 없다(대판 2005.3.24. 2004다65367).

6. 채권자취소소송에서 피보전채권의 추가·교환·승계

(1) 피보전채권의 추가·교환이 소변경인지 여부

- 채권자가 사해행위취소 및 원상회복청구를 하면서 보전하고자 하는 채권을 추가하거나 교환하는 것은 사해행위취소권과 원상회복청구권을 이유 있게 하는 공격방법에 관한 주장을 변경하는 것일 뿐이지 소송물 또는 청구 자체를 변경하는 것이 아니므로, 채권자가 보전하고자 하는 채권을 달리하여 동일한 법률행위의 취소 및 원상회복을 구하는 채권자취소의 소를 이중으로 제기하는 경우 전소와 후소는 소송물이 동일하다고 보아야 하고, 이는 전소나 후소 중 어느 하나가 승계참가신청에 의하여 이루어진 경우에도 마찬가지이다(대판 2012.7.5. 2010다80503).

(2) 피보전채권의 추가·교환의 경우 제소기간의 준수 여부

- 채권자취소소송을 제기한 후에 피보전채권을 추가·교환하는 것은 소송물을 변경하는 것이 아니므로 추가·교환시점이 아닌 소제기 시를 기준으로 제소기간 준수 여부를 판단해야 한다.

(3) 다른 채권자의 피보전채권을 승계하여 소송하는 경우

- 피보전채권은 채권자취소소송의 소송물과 관계없으므로 채권자가 자기의 채권을 피보전채권으로 취소소송을 하다가 다른 채권자의 취소소송에 승계참가한 경우 선행 취소소송이 확정되면 후행 취소소송은 기판력을 받게 된다.

V. 판결의 무효

1. 판결의 부존재

- 판결로서 성립하기 위한 기본적인 요건을 흠결하여 법률상 판결로서의 존재를 인정할 수 없는 경우를 판결의 부존재라고 한다. 판결의 부존재는 법률상 판결이 존재하지 않는 것이므로 판결로서 아무런 효력이 없으며 상소의 대상이 되지 아니한다. 다만, 당사자는 당해 심급에서 절차가 완결된 것이 아니므로 기일지정신청으로 절차의 속행을 구할 수 있다.

2. 무효의 판결

(1) 의의

- 판결의 당연무효란 판결로서의 외관을 갖추었지만 그 내용상 중대한 하자가 있어서 판결의 내용상 효력인 기판력·집행력·형성력 등이 발생하지 아니하는 경우를 말한다.

(2) 무효사유

- ❶ 재판권이 흠결되어 있는 경우, ❷ 실재하지 않는 자에 대한 판결, ❸ 현행법상 인정되지 않는 법률효과를 인정하는 판결, ❹ 소제기 없이 판결하는 경우, ❺ 판결내용의 불명확으로 그 의미를 확정할 수 없는 판결 등이 이에 해당한다.

(3) 효력

- 무효인 판결의 확정 전에 상소로 다툴 수 있는지 여부에 대해 판례는 부정하나 학설은 판결의 부존재의 경우와는 달리 기속력, 형식적 확정력이 발생하고 부당집행의 우려를 방지하기 위한 외관제거의 필요성상 상소는 허용되므로 상소심은 상소를 인용하고 그 무효인 판결을 취소하고 소각하판결을 해야 한다고 한다. 다만, 학설·판례에 의하면 소송계속이 종료되었음을 간과한 판결에 대해 상소를 제기하면 상소심은 원판결을 취소하고 소송종료선언을 해야 한다. 무효인 판결의 확정 후에는 재심의 대상이 되지 아니하므로 재심으로 다툴 수 없고 별소로 다툴 수 있을 뿐이다.

3. 판결의 편취

(1) 편취판결의 의의

- 판결의 편취란 당사자가 상대방이나 법원을 기망하여 부당한 내용의 판결을 받는 것을 말한다.

(2) 편취판결의 유형

- 이에는 ❶ 다른 사람의 성명을 모용하여 판결을 받는 성명모용자송달에 의한 편취판결, ❷ 소취하합의를 위반하여 소를 취하함이 없이 피고의 불출석을 기화로 승소판결을 받는 소취하합의 위반에 의한 편취판결, ❸ 원고가 피고의 주소를 알고 있음에도 주소불명으로 속여 공시송달명령을 받아 피고 모르게 승소판결을 받는 공시송달에 의한 편취판결, ❹ 원고가 피고의 주소를 허위로 기재하여 그 주소에 소장부본을 송달케 하고 원고 자신이 송달받아 자백간주로 승소판결을 받는 허위주소송달에 의한 편취판결, ❺ 피고의 대표자를 참칭대표자로 적어 송달되게 하여 자백간주로 승소판결을 받는 참칭대표자송달에 의한 편취판결 등이 포함된다.

(3) 편취판결의 효력

- 판결이 편취된 경우 피고의 재판을 받을 권리가 실질적으로 보장된 것이 아니므로 당연무효로 보아야 한다는 무효설이 주장되고 있으나, 판결 자체는 유효하다는 것이 학설·판례의 일반적인 태도이다. 생각건대 판결편취의 경우 민사소송법 제451조 제1항이 당연무효가 아니라는 전제에서 재심사유로 규정하고 있으므로 유효설이 타당하다고 판단된다.

(4) 구제수단

① 소송법적 구제수단

㉮ 문제점

- 소송법적 구제수단으로는 상소추후보완·재심 또는 항소제기를 고려할 수 있다. 편취판결의 유형 중 성명모용자송달에 의한 편취판결, 소취하합의 위반에 의한 편취판결의 경우에는 허위주소송달이나 공시송달방법을 이용할 것이므로 공시송달이나 허위주소송달, 참칭대표자에의 송달의 효력에 따라 각각의 편취판결에 대한 소송법적 구제수단이 문제된다.

㉯ 학설

- 판결편취의 경우 판결정본의 송달은 무효이어서 상소기간은 진행하지 아니하므로 그 판결에 대하여 항소만 할 수 있다는 항소설과 판결편취의 경우에도 판결정본의 송달은 유효하여 상소기간이 진행하므로 상소기간이 도과하면 추후보완상소 또는 재심의 소를 제기해야 한다고 하는 상소추후보완・재심설이 대립하고 있다.

㈐ 판례

㉠ 성명모용자송달에 의한 편취판결

- 제3자가 피고를 참칭, 모용하여 소송을 진행한 끝에 판결이 선고되었다면 피모용자인 피고는 그 소송에 있어서 적법하게 대리되지 않는 타인에 의하여 소송절차가 진행됨으로 말미암아 결국 소송관여의 기회를 얻지 못하였다 할 것이니 피고는 상소 또는 재심의 소를 제기하여 그 판결의 취소를 구할 수 있다(대판 1964.11.17. 64다328)

㉡ 공시송달에 의한 편취판결

- 공시송달의 방법에 의하여 판결정본이 송달된 경우 피고의 주소지를 허위로 하여 소가 제기된 경우라 하더라도 그 송달은 유효한 것이고 그때부터 상소제기기간이 도과되면 그 판결은 확정되는 것이므로 피고는 재심의 소(민소법 제451조 제1항 제11호)를 제기하거나 추완항소를 제기하여 그 취소・변경을 구하여야 한다(대판 1980.7.8. 79다1528).

㉢ 허위주소송달에 의한 편취판결

- 편취판결의 경우에 있어서는 판결정본이 제소자가 허위로 표시한 상대방의 허위주소로 보내져서 상대방 아닌 다른 사람이 그를 수령한 것이니 상대방에 대한 판결정본의 송달은 부적법하여 무효이고 상대방은 아직도 판결정본의 송달을 받지 않은 상태에 있는 것으로서 그 판결에 대한 항소기간은 진행을 개시하지 않은 것이라고 보아야 할 것이다. 그렇다면 본건 편취판결은 형식적으로 확정된 확정판결이 아니어서 기판력이 없는 것이라고 할 것이고 민사소송법 제451조 제1항 제11호에 당사자가 상대방의 주소 또는 거소를 알고 있었음에도 불구하고... 허위의 주소나 거소로 하여 소를 제기한 때를 재심사유로 규정하고 있으나 이는 공시송달의 방법에 의하여 상대방에게 판결정본을 송달한 경우를 말하는 것이고, 본건 편취판결에 있어서와 같이 공시송달의 방법에 의하여 송달된 것이 아닌 경우까지 재심사유가 되는 것으로 규정한 취지는 아니라고 할 것이며 따라서 항소설에 따른 본원판결 즉 본건과 같은 편취판결은 확정판결이 아니어서 기판력이 없다는 본원판결 등은 정당하다. 그뿐만 아니라 본건 편취판결이 형식적으로 확정되어 기판력이 있는 것으로 판단한 원심의 조처에는 판결의 확정력 내지는 기판력에 관한 법리를 오해한 위법을 범한 것이라고 할 것이고 또 본건 편취판결에 기판력이 부정된다면 본건 편취판결에 의거하여 피고 명의로 경료된 본건 부동산에 관한 소유권이전등기는 실체적 권리관계에 부합될 수 있는 다른 사정이 없는 한 말소될 처지에 있는 것이어서 원고가 본건 편취판결에 대하여 항소를 제기하지 아니하고 본건 편취판결을 그대로 둔 채 별소인 본건 소에서 본건 청구를 한다고 하여도 피고로서는 이를 거부할 수 없는 것이라고 할 것이다(대판 1978.5.9. 75다634[전합]). 판례는 허위주소송달에 의한 편취판결의 경우 항소나 별소제기에 의하여 구제될 수 있음을 분명히 하였다고 판단된다.

㉣ 참칭대표자송달에 의한 편취판결

- 참칭대표자를 대표자로 표시하여 소송을 제기한 결과 그 앞으로 소장부본 및 변론기일소환장이 송달되어 변론기일에 참칭대표자의 불출석으로 의제자백 판결이 선고된 경우, 이는 적법한 대표자가 변론기일소환장을 송달받지 못하였기 때문에 실질적인 소송행위를 하지 못한 관계로 위 의제자백 판결이 선고된 것이므로, 민사소송법 제451조 제1항 제3호 소정의 재심사유에 해당한다(대판 1999.2.26. 98다47290).

㈑ 검토

- 항소설에 의하면 당사자는 언제든지 항소할 수 있어 불안정한 법률상태가 계속되므로 원칙적으로 재심설이 타당하다고 보인다. 따라서 각각의 편취판결의 경우 판결의 확정 전에는 상소, 판결의 확정 후에는 추후보완상소(민소법 제173조)나 재심의 소(민소법 제451조 제1항 제3호)에 의하여 구제받을 수 있다. 다만, 허위주소 송달에 의한 판결편취의 경우에는 송달 자체가 없었다고 볼 수 있으므로 항소설을 취하여 항소에 의하여 구제받는 것이 타당하다고 판단된다.

② 실체법적 구제수단

㈎ 문제점

- 편취판결에 의하여 집행이 이루어진 경우 편취판결을 재심으로 취소하지 않고 바로 실체법적 구제수단인 손해배상청구나 부당이득반환청구, 말소등기청구를 할 수 있는지 문제된다.

㈏ 학설

- 편취판결도 기판력이 발생하므로 재심의 소에 의해 판결을 취소하지 아니하면 손해배상청구나 부당이득반환청구, 말소등기청구가 불가능하다는 재심필요설, 편취판결을 기판력으로 보호하는 것은 자연적 정의에 반하는 것이므로 별도의 재심의 소를 제기함이 없이 위와 같은 실체법상 구제수단을 강구할 수 있다는 재심불요설, 기본적으로 재심필요설을 취하면서 당사자의 절차기본권과 관련하여 제한적으로 재심이 필요 없다는 제한적 재심불요설이 대립하고 있다.

㈐ 판례

㉠ 부당이득반환청구・말소등기청구 - 재심필요설

- 판례는 대여금 중 일부를 변제받고도 이를 속이고 대여금 전액에 대하여 소송을 제기하여 승소 확정판결을 받은 후 강제집행에 의하여 위 금원을 수령한 채권자에 대하여, 채무자가 그 일부 변제금 상당액은 법률상 원인 없는 이득으로서 반환되어야 한다고 주장하면서 부당이득반환 청구를 하는 경우, 그 변제주장은 대여금반환청구소송의 확정판결 전의 사유로서 그 판결이 재심의 소 등으로 취소되지 아니하는 한 그 판결의 기판력에 저촉되어 이를 주장할 수 없으므로, 그 확정판결의 강제집행으로 교부받은 금원을 법률상 원인 없는 이득이라고 할 수 없다(대판 1995.6.29. 94다41430)고 하여 재심필요설의 태도를 취하고 있다. 다만, 허위주소송달에 의한 편취판결의 경우 피고 명의로 경료된 본건 부동산에 관한 소유권이전등기는 실체적 권리관계에 부합될 수 있는 다른 사정이 없는 한 말소될 처지에 있는 것이어서 원고가 본건 편취판결에 대하여 항소를 제기하지 아니하고 본건 편취판결을 그대로 둔 채 별소인 본건 소에서 본건 청구를 한다고 하여도 피고로서는 이를 거부할 수 없는 것이라고 하여(대판 1978.5.9. 75다634[전합]) 재심의 소 제기 없이 별소제기에 의하여 구제될 수 있음을 분명히 하였다.

㉡ 불법행위로 인한 손해배상청구 - 제한적 재심불요설

- 판례는 편취된 판결에 기한 강제집행이 불법행위로 되는 경우가 있다고 하더라도 당사자의 법적 안정성을 위해 확정판결에 기판력을 인정한 취지나 확정판결의 효력을 배제하기 위하여는 그 확정판결에 재심사유가 존재하는 경우에 재심의 소에 의하여 그 취소를 구하는 것이 원칙적인 방법인 점에 비추어 볼 때 불법행위의 성립을 쉽게 인정하여서는 아니 되고, 확정판결에 기한 강제집행이 불법행위로 되는 것은 당사자의 절차적 기본권이 근본적으로 침해된 상태에서 판결이 선고되었거나 확정판결에 재심사유가 존재하는 등 확정판결의 효력을 존중하는 것이 정의에 반함이 명백하여 이를 묵과할 수 없는 경우로 한정하여야 한다(대판 1995.12.5. 95다21808)고 하여 제한적 재심불요설을 취하고 있다.

㈑ 검토

- 편취판결이라고 하더라도 효력이 있으므로 원칙적으로 재심의 소를 제기하여야 하나 당사자의 절차적 기본권이 본질적으로 침해되는 예외적 상황에서는 재심의 소에 의해 판결을 취소함이 없이 실체법적 구제수단을 통하여 구제를 받을 수 있다고 보아야 하므로 부당이득반환청구, 말소등기청구의 경우와 불법행위로 인한 손해배상청구의 경우를 구별하는 판례의 태도가 타당하다. 다만, 판례는 피고들이 재심대상판결의 취소와 그 본소청구의 기각을 구하는 외

에, 원고와 승계인을 상대로 재심대상판결에 의하여 경료된 원고 명의의 소유권이전등기와 그 후 승계인의 명의로 경료된 소유권이전등기의 각 말소를 구하는 청구를 병합하여 제기하고 있으나, 그와 같은 청구들은 별소로 제기하여야 할 것이고 재심의 소에 병합하여 제기할 수 없다(대판 1997.5.28. 96다41649)고 하여 재심의 소와 관련 청구의 병합제기를 부정하고 있음을 유의하여야 한다.

③ 집행법적 구제수단

㉮ 문제점

- 편취판결의 집행이 종료되기 전 집행단계에서 청구이의의 소를 제기하여 집행을 막을 수 있는지 문제된다. 이는 이의원인은 확정된 청구가 변론종결 후에 변경・소멸된 경우와 같이 변론종결 뒤의 이유이어야 하기 때문이다(민사집행법 제44조 제2항).

㉯ 인정 여부

㉠ 학설

- 구체적 타당성을 강조하여 편취판결을 집행하는 것은 부당집행이므로 부당집행을 문제 삼는 것은 청구이의의 사유가 된다는 긍정설과 법적 안정성을 강조하여 판결편취사실은 전소변론종결 전의 사유이므로 청구이의의 사유가 될 수 없다는 부정설이 대립하고 있다.

㉡ 판례

- 판례는 민사집행법 제44조에서 청구에 관한 이의의 소를 규정한 것은 부당한 강제집행이 행하여지지 않도록 하려는 데 있다 할 것으로 판결에 의하여 확정된 청구가 그 판결의 변론종결 후에 변경・소멸된 경우뿐만 아니라 판결을 집행하는 자체가 불법한 경우에는 그 불법은 당해 판결에 의하여 강제집행에 착수함으로써 외부에 나타나 비로소 이의의 원인이 된다고 보아야 하기 때문에 이 경우에도 이의의 소를 허용함이 상당하다 할 것(대판 1984.7.24. 84다카572)이라고 하고 있다. 다만 대지에 대한 수분양자 명의변경 절차의 이행을 소구함은 채무자의 의사의 진술을 구하는 소송으로서 그 청구를 인용하는 판결이 선고되고 그 소송이 확정되었다면, 그와 동시에 채무자가 수분양자 명의변경 절차의 이행의 의사를 진술한 것과 동일한 효력이 발생하는 것이므로 위 확정판결의 강제집행은 이로써 완료되는 것이고 집행기관에 의한 별도의 집행절차가 필요한 것이 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 위 확정판결 이후에 집행절차가 계속됨을 전제로 하여 그 채무명의가 가지는 집행력의 배제를 구하는 청구이의의 소는 허용될 수 없다(대판 1995.11.10. 95다37568)고 하고 있음을 유의하여야 한다.

㉢ 검토

- 생각건대 그 불법의 정도가 심해서 기판력의 보호를 받는 것이 불합리한 경우에는 그때의 강제집행은 권리남용이 되어 청구이의의 소에 의한 구제를 허용할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

㉣ 인정요건

- 확정판결에 따른 강제집행이 권리남용에 해당한다고 하기 위해서는 확정판결의 내용이 실체적 권리관계에 배치되는 경우로서 그에 기한 집행이 현저히 부당하고 상대방으로 하여금 집행을 수인하도록 하는 것이 정의에 반함이 명백하여 사회생활상 용인할 수 없다고 인정되는 것과 같은 특별한 사정이 있어야 한다. 그리고 이때 확정판결의 내용이 실체적 권리관계에 배치된다는 점은 확정판결에 기한 강제집행이 권리남용이라고 주장하며 집행 불허를 구하는 자가 주장・증명하여야 한다(대판 2017.9.21. 2017다232105).